12 Sesiones de Derecho de Daños (18.9.2012).pdf

12 SESIONES DE DERECHO DE DAÑOS

PARA UN CURSO TRIMESTRAL

DE

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS [DEL DERECHO ESPAÑOL]

DE

LA RESPONSABILIDAD CIVIL

PABLO SALVADOR CODERCH
CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL
ABOGADO
FUNDADOR Y *SENIOR EDITOR* DE INDRET

CARLOS GÓMEZ LIGÜERRE
PROFESOR TITULAR DE DERECHO CIVIL

ANTONI RUBÍ PUIG
DOCTOR, PROFESOR LECTOR DE DERECHO CIVIL

SONIA RAMOS GONZÁLEZ
DOCTORA, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA "RAMÓN Y CAJAL"

ANTONI TERRA IBÁÑEZ
DOCTORANDO EN DERECHO Y ESTUDIANTE DE ECONOMÍA

Universitat Pompeu Fabra

Curso 2012-2013

SESIÓN 1ª

1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DE DAÑOS..... 8

1.1. ¿Qué es la responsabilidad civil? / *What is a Tort?* 9
1.1.1. Atropello múltiple en la estación de ferrocarril de Castelldefels, Barcelona (23.6.2010) 9
1.1.2. Accidente de ferrocarril 12
1.1.3. Infracción de deberes de información / *Failure to warn* 14

1.2. Fuentes primarias y secundarias/ *Primary and Secondary Sources* 15
1.2.1. Legislación / *Statutes* 15
1.2.2. Jurisprudencia / *Case-law* 16
1.2.3. Doctrina / *Secondary Literature or Secondary Sources* 16

1.3. Análisis económico del derecho/*Law and Economics* 18

1.4. El concepto, las clases de accidente y las limitaciones del derecho de daños. La minimización de los costes sociales de los accidentes 19
1.4.1. El concepto y las clases de accidente 19
1.4.2. Algunas limitaciones del derecho privado de daños 20
1.4.3. La minimización de los costes sociales de los accidentes (Guido Calabresi, 1970; Steven Shavell, 2004) y las simplistas pero escasamente realistas asunciones iniciales de los modelos analíticos del moderno derecho de daños .. 20

SESIÓN 2ª

1.5. Las cuatro grandes reglas de responsabilidad: no responsabilidad, dolo, culpa o negligencia y responsabilidad objetiva / *Basis: No Liability, Intentional Torts, Negligent Torts, and Strict Liability.* El límite de la responsabilidad absoluta 22
1.5.1. La regla de la ausencia de responsabilidad (*No liability*): sobre la libertad de actuar sin miedo a sus consecuencias dañinas para terceros 22
1.5.2. La causación dolosa, intencional, de daños 24
1.5.3. La regla de la negligencia 25
1.5.4. La regla de la responsabilidad objetiva 27

1.6. Tipos de daño / *Types of Harm* 29
1.6.1. Análisis doctrinal / *Doctrinal Analysis* 29
1.6.2. Análisis económico del derecho / *Economic Analysis of Law* 31

1.7. Responsabilidad civil y penal / *Tort and Crime* 32

1.8. Responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad (también civil, pero) contractual / *Tort and Contract* 32

1.9. ¿Es el derecho de daños una especialidad bien definida? 36

1.10. ABC de un pleito de daños 37

SESIÓN 3ª

2. NEGLIGENCIA 38

2.1. Panorama de la negligencia: la negligencia como infracción de deberes de precaución 38
2.1.1. Negligencia y circunstancias personales del causante 41
2.1.1.1. Edad, minoría de edad, estado de salud 41
2.1.1.2. Edad, salud y responsabilidad civil en el derecho comparado 44
2.1.1.2.a Common Law 44
a) *Daniels v. Evans* (224 A.2d 63 (N.H. 1966)) 44
b) *Purtle v. Shelton* (474 S.W.2d 123 (Ark. 1971)) 46
2.1.1.2.b Civil Law: Francia y Alemania 47
2.1.1.2.c Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbusch (BGB)) 48
2.1.1.3. Víctimas especialmente sensibles. Eggshell Skull Doctrine or The Thin Skull Rule or You take your victim as you find him 48
2.1.1.4. Negligencia y riqueza del causante 48
2.1.1.5. Conocimientos especiales y habilidades particulares del demandado (o su ausencia) 49
2.1.1.6. Situaciones de peligro que requieren acción inmediata: Sudden emergency doctrine 50

SESIÓN 4ª

2.2. Cálculo del riesgo. Concepto económico de culpa / *Calculus of risk. The Economic Concept of Negligence* 53
2.2.1. *Eckert v. Long Island R.R.* (43 N.Y. 502 (1871)) 53
2.2.2. STS, 1ª, 1186/2004, de 10 de diciembre 54
2.2.3. *United States v. Carroll Towing Co.* (159 F.2d 169 (2d Cir. 1947)) 55

2.3. Negligencia como incremento irrazonable de riesgo / *Negligence as non-reasonable increase of risk* 58
2.3.1. *Helling v. Carey* (83 Wash. 2d 514, 519 P.2d 981 (1974)) 58
2.3.2. STS, 3ª, de 26 de junio de 2008. *Octavio c.Ministerio de Sanidad y Consumo* 59
2.3.3. STS, 1ª, 150/2008, de 28 de febrero 60
2.3.4. STS, 1ª, 64/2011, de 9 de febrero 60
2.3.5. STS, 1ª, 149/2010, de 25 de marzo 61

2.4. Costumbre / *Custom* 61
2.4.1. *The T.J. Hooper* (60 F.2d 737 (2d Cir.), cert. denied, 287 U.S. 662 (1932)) . 62
2.4.2. Pablo SALVADOR CODERCH/Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, "Instrumentos de control social y derecho de daños", *InDret* 4/2004 (www.indret.com), pp. 10-12 64

SESIÓN 5ª

2.5. Negligencia per se. Infracción de normas legales. Presunciones 67
2.5.1. *Gorris v. Scott* (L.R. 9 Ex. 125 (1874)) 69
2.5.2. *Martin v. Herzog* (126 N.E. 814 (N.Y. 1920)) 70

2.5.3. *Tedla v. Ellman* (280 N.Y. 124, 19 N.E.2d 987 (1939)) 71
2.5.4. *Brown v. Shyne* (151 N.E. 197 (N.Y. 1926)) 73
2.5.5. SAP de Almería, Secc. 2ª, Penal, 286/2000, de 3 de julio 75
2.5.6. *Uhr v. East Greenbush Cent. Sch. Dist.* (720 N.E.2d 886 (N.Y. 1999)) 79
2.5.7. STS, 1ª, 909/2005, de 9 de noviembre 82
2.5.8. STS, 1ª, 17/2004, de 3 de febrero 82
2.5.9. *Preemption* 83

2.6. *Res ipsa loquitur* 87
2.6.1. *Byrne v. Boadle* (159 Eng. Rep. 299 (Ex. 1863)) 87
2.6.2. *Colmenares Vivas v. Sun Alliance Insurance Co.* (807 F.2d 1102 (1st Cir. 1986)) 88
2.6.3. *Ybarra v. Spangard* (25 Cal.2d 486, 154 P.2d 687) 91
2.6.4. STS, 1ª, 1146/1998, de 9 de diciembre 92
2.6.5. STS, 1ª, 461/2003, de 8 de mayo: fractura de rodilla 92
2.6.7. Otras sentencias sobre responsabilidad médica por daños desproporcionados 93
STS, 1ª, 417/2007, de 16 de abril 93

SESIÓN 6ª

2.7. Negligencia bilateral / *Bilateral Care or Joint Care* 95
2.7.1. Negligencia contributiva / *Contributory Negligence* 95
2.7.1.a) Butterfield v. Forrester (103 Eng. Rep. 926 (K.B. 1809)) 95
2.7.1.b) LeRoy Fibre Co. v. Chicago, Milwaukee & St. Paul Ry., 232 US. 340 (1914) 96
2.7.1.c) STS, 1ª, 3 de junio de 1901. Colección Legislativa, 91 p. 867 97
2.7.1.d) STS, 4ª, 6 de julio de 1990. Inexistencia de error judicial al presentar un documento en idioma extranjero sin acompañar traducción 98
2.7.2. The Last Clear Chance Doctrine 100
2.7.2.a) Davies v. Mann (152 Eng. Rep. 588) 100
2.7.2.b) Restatement (Second) of Torts (1965, updated April 2012) 100
2.7.3. Negligencia comparativa o concurrencia de culpas / *Comparative Negligence* 101
2.7.3.a) Antonio FERNÁNDEZ/Víctor M. SÁNCHEZ (2003), "Negligencia Multilateral en Accidente de Motocicleta, ¿cuál es el Estándar Óptimo de Responsabilidad?", InDret 3/2003, (www.indret.com), pp. 10-11 101
2.7.3.b1) STS, 1ª, 967/2002, de 21 de octubre. Accidente de tráfico por colisión de una motocicleta con un montón de grava y arena 102
2.7.3.b2) STS, 1ª, 139/2011, de 14 de marzo 103
2.7.3.c) Negligencia comparativa modificada 105

2.8. Consentimiento de la víctima y asunción del propio riesgo / *Victim's consent and assumption of risk / Einverständigung, Tatbestand-ausschließenden Einwilligung und Handeln auf eigene Gefahr* 107
2.8.1. *Knight v. Jewett* (3 Cal. 4th 296, 834 P.2d 696, 11 Cal. Rptr. 2d 2 (1992)) 108
2.8.2. STS, 1ª, 931/2001, de 17 de octubre 108
2.8.3. STS, 1ª, 580/2006, de 31 de mayo 108
2.8.4. STS, 1ª, 270/2006, de 9 de marzo 108

SESIÓN 7ª

3. CAUSALIDAD / *CAUSATION* **111**
3.1.1. Causalidad y omisión 112
3.1.2. Causalidad múltiple 116
3.1.3. Causalidad indeterminada 117

3.2. Causalidad y su construcción social. Ciencia y cultura / *Cause in fact and the social construction of causation. Science and Culture* 118

3.3. Causalidad alternativa / *Alternative Causation* 119
3.3.1. *Summers v. Tice* (33 Cal. 2d 80, 199 P.2d 1 (1948)) 119
3.3.2 *Ybarra v. Spangard* (*25 Cal.2d 486, 154 P.2d 687*) 121

3.4. Causalidad concurrente / *Concurrent Causation* 122
3.4.1 *Kingston v. Chicago Ry.* (191 Wis. 610, 211 N.W. 913 (1927)) 122
3.4.2. STS, 1ª, 816/2011, de 6 de febrero 123
3.4.3. STS, 1ª, 425/2009, de 4 de junio 125
3.4.4. STS, 1ª, 485/2008, de 28 de mayo 125
3.4.5. *Dillon v. Twin State* (85 N.H. 449, 163 A. 111 (1932)) 126

3.5. Causalidad sucesiva / *Succesive Causation* 128
3.5.1. BGH NJW 1952, 1010 128
3.5.2. *Baker v. Willoughby* ([1970] 2 W.L.R. 50) 128
3.5.3. STS, 1ª, 461/2003, de 8 de mayo:fractura de rodilla en accidente de esquí y responsabilidad civil médico-sanitaria. 128

3.6. Causalidad probabilística / *Probabilistic Causation* 129

SESIÓN 8ª

3.7. Imputación objetiva / *Proximate Causation; Scope of Liability* 132
3.7.1. Previsibilidad / *Foreseeability* 132
3.7.1.a) Palsgraf v. Long Island R.R. (N248 N.Y. 339, 162 N.E. 99 (1928)) 132
3.7.1.b) STS, 1ª, 19.7.1996 (RJ 1996, 5654) 134
3.7.2. Proximate Cause / Causalidad Adecuada / *Adäquanztheorie* 134
3.7.2.a) Stahlecker v. Ford Motor Company (266 Neb. 601, 667 N.W.2d 244 (2003)) 134
3.7.2.b) STS, 1ª, 255/1997, de 1 de abril 136
3.7.2.c) STS, 1ª, 377/2004, de 12 de mayo 136
3.7.2.d) STS, 3ª, de 18 de mayo de 2010 137
3.7.3. Riesgos generales de la vida / *General Life Risks* / *Erlaubte Risiken* 138
3.7.3.a) STS, 3ª, 29 de octubre de 1998 138
3.7.3.b) STSJ Comunidad Valenciana, Sala C-A, Secc. 1ª, 55/2003, de 2 de enero 139
3.7.4. Prohibición de regreso y posición de garante / *Remoteness* / *Regressverbot und Garantenstellung* 139
3.7.5. Ámbito de protección de la norma / *Harm within the Risk* / *Schutzbereich der Norm* 140
3.7.5.a) STS, 1ª, 902/1998, de 8 de octubre 140
3.7.5.b) STS, 3ª, 3 de noviembre de 2008 140

3.7.6. Provocación / *Provocation* / *Herausforderung* 140
3.7.6.a) STS, 2ª, de 26 de septiembre de 2005 140

SESIÓN 9ª

4. RESPONSABILIDAD OBJETIVA / *STRICT LIABILITY* 142

4.1. § 20 RTT. Abnormally Dangerous Activities 142

4.2. Poseedor de un animal / *Custody of animals* 144
4.2.1. Artículos 1905-6 CC. Llei 10/1999, de 30 de juliol 145
4.2.2. §§ 21 and ff. RTT 145
4.2.3 STS, 1ª, 1384/2007, de 20 de diciembre 145
4.2.4 Jurisprudencia menor sobre responsabilidad del poseedor de animales. 146

4.3. Objetos arrojados / *Falling objects* 151
4.3.1. Artículo 1910 CC 151
4.3.2. STS, 1ª, 1243/2007, de 4 de diciembre 151

4.4. Responsabilidad de las Administraciones Públicas / *Governmental Liability* 152
4.4.1. Artículo 139.1 de la Ley 30/1992 152
4.4.2. Artículo 141.1 de la Ley 30/1992 152
4.4.3.STS, 1ª, 1186/2004, de 10 de diciembre 152

4.5. Circulación de vehículos / *Driving* 153

4.6. Responsabilidad por producto defectuoso / *Products Liability* 154
4.6.1. Artículo 135 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 154
4.6.2. Artículo 1 de la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (modificada por Directiva 1999/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 1999) 154

4.7. La doble justificación de la responsabilidad objetiva / *The dual justification of SL: Rylands v. Fletcher* 154
4.7.1. Rylands v. Fletcher ([1868] UKHL 1) 154
4.7.2. Restatement (Second) of Torts (1977) 156

SESIÓN 10ª

5. DAÑO / *DAMAGES* 158

5.1. Categorías de daño / *Harm and damages tipology* 158

5.2. Daños compensatorios: lesiones personales y mitigación / *Compensatory damages: personal injury and mitigation* 158

5.2.1. *Williams v. Bright* (632 N.Y.S.2d 760 N.Y.Sup.,1995) 158
5.2.2. STC 154/2002, de 18 de julio 160

5.3. Compatibilidad de fuentes indemnizatorias / *Collateral Source Rule* 163

5.4. Daño moral y lucro cesante / *Pain and Suffering and Lost earning and Impairment of Earning Capacity* 165
5.4.1. *Walters v. Hitchcock* (237 Kan. 31, 697 P.2d 847 (1985)) 166
5.4.2. *Hawkins v. McGee* (1929), the "Hairy Hand Case" 168
5.4.3. Lucro cesante y víctimas menores de edad 168
5.4.3. Lucro cesante y víctimas menores de edad 169
5.4.4. Daño moral autónomo 169
5.4.5. Nacimiento indebido/ *Wrongful birth* 170

5.5. Daño puramente económico / *Pure Economic Loss* 171

5.6. Pérdida de oportunidad 172
5.6.1. Infracción del consentimiento informado. STS, 1ª, 488/2006, de 10 de mayo 172
5.6.2. Error en el tratamiento médico. STS, 3ª, 26 de junio de 2008 173

SESIÓN 11ª

6. RESPONSABILIDAD POR HECHO AJENO / *VICARIOUS LIABILITY* 175

6.1. Pablo Salvador Coderch *et alii.*, "Respondeat Superior I", InDret 2/2002 (www.indret.com), pp. 6-10 175

6.2. STS, 1ª, 545/2007, de 17 de mayo 178

6.3. STS, 1ª, 1070/2007, de 16 de octubre 179

6.4. STS, 1ª, 1006/2006, de 2 de enero 179

6.5. STS, 1ª, 27.1.2006 (Ar. 615). MP: Pedro González Poveda 180

6.6. STS, 1ª, 226/2006, de 8 de marzo 181

6.7. STS, 2ª, 388/2004, de 25 de marzo 182

SESIÓN 12ª

7. PRESCRIPCIÓN / *STATUTE OF LIMITATIONS* 183

Sesión 1ª

1. Introducción al derecho español de daños

Preliminar: cuatro buenas maneras de estructurar el análisis de los casos en derecho y en derecho de daños

IRAC: el punto de vista del jurista

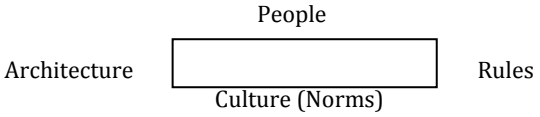
a) *Issue*: ¿cuál es o cuáles son las cuestiones legales que plantean los hechos alegados y probados por las partes en el caso?
b) *Rules*: ¿cuáles son las reglas de derecho aplicables a los hechos del caso? En su caso: ¿cuál es la jurisprudencia?
c) *Analysis*: ¿Cuáles son las razones, en derecho, de las partes, de cada una de ellas?
d) *Conclusion*: ¿Qué concluiría el Juez o Tribunal en un caso como el presentado o qué habría de haber resuelto?

Lecciones para el futuro: el punto de vista del ingeniero:

J. BUONGIORNO, R. BALLINGER, M. DRISCOLL, B. FORGET, C. FORSBERG, M. GOLAY, M. KAZIMI, N. TODREAS, J. YANCH,*Technical Lessons Learned from the Fukushima-Daichii Accident and Posible Corrective Actions for the Nuclear Industry: An Initial Evaluation*, Nuclear Science & Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Canes publications, May 2011
http://web.mit.edu/nse/pdf/news/2011/Fukushima_Lessons_Learned_MIT-NSP-025.pdf

a) Observations from the accident
b) Key questions
c) Possible corrective actions
d) Possible design improvements in the future

PARC: El punto de vista del científico social:



"Look, no hands", *The Economist*, September 1st 2012 (http://www.economist.com/node/21560989): cada mes mueren en el mundo 108.000 personas en accidentes de tráfico (WORLD HEALTH ORGANISATION, GLOBAL HEALTH OBSERVATORY DATA REPOSITORY, *Mortality and burden of disease, Cause-specific mortality*, 2008, http://apps.who.int/ghodata[1]). Si se mantiene el ritmo creciente de producción de automóviles, en 2020 la cifra mensual de muertos por accidentes de tráfico sobrepasará los 150.000. Sin embargo, las ayudas electrónicas a la conducción y hasta el pilotaje automático ayudarán a reducir el número y gravedad de los accidentes de tráfico, un ejemplo claro de cambio en la arquitectura. A mejor.

[1] Hay un error de cálculo en el artículo de *The Economist*. El estudio de WHO se expresa en términos anuales: 1.208.691 fallecidos por accidentes de tráfico en 2008, es decir, **100.724 al mes**, y no 108.000. También cabe reseñar que este documento, que sirve de fuente a *The Economist*, se refiere a cifras globales de 2008, por lo que es aventurado afirmar en 2012, como lo hace el texto, que la media actual de muertes por accidentes de tráfico sigue siendo la misma.

Redacción legal: el punto de vista del escritor legal:

Distribuye tu tiempo disponible, de acuerdo con la regla de las cinco E's (PSC (1985)):

- Escucha (mucha gente espera, ansiosa, su turno para hablar, no escuchan).

- Estudia (ni el mejor redactor legal está solo en el mundo, solo lo está ante la pantalla: acompáñala con la mejor literatura, dos referencias de primer nivel suelen bastar, pero busca las mejores). Si el texto que has de escribir es un examen o prueba, las dos primeras E's pueden colapsar en una: Entiende las preguntas que te formulan.

- Esquematiza (prepara, por escrito, un esquema de tu discurso. La organización triádica es ideal: nadie recuerda un discurso basado en siete principios. El ejemplo clásico de buen discurso estructurado en bloque de tres ideas en la década de los dos miles es el Steve Jobs, *How to Live Before You Die* (accesible en la red. Por ejemplo, en TED Ideas Worth Spreading).

- Escribe (al final, las palabras son el arma principal del abogado, del juez. Y un buen test para un Estado de derecho es calificar de 0 a 10 el grado de coherencia entre las palabras del juez y las verdaderas razones de su decisión. ¿Aprobamos en España?).

- Edita (dedica por lo menos una cuarta parte de tu tiempo a editar el texto que has redactado; hay algunas buenas maneras de editar: una es dejar que lo haga otra persona mayor o más joven que tú; otra, que lo hagas tú al día siguiente de haber redactado el primer borrador).

Las cinco reglas anteriores, las cinco E's ayudan a evitar errores. Hay una sexta que es solo para profesionales auténticos, para maestros:

- ¡Empieza de nuevo!

Un buen libro para aprender a escribir en derecho es el de Terrill POLLMAN, Judith M. STINSON, Richard K. NEUMANN, Jr., Elisabeth POLLMAN, *Legal Writing*, 1st edition, Wolters Kluwer, New York, 2011.

1.1. ¿Qué es la responsabilidad civil? / *What is a Tort?*

1.1.1. Atropello múltiple en la estación de ferrocarril de Castelldefels, Barcelona (23.6.2010)

http://www.youtube.com/watch?v=_HSmGph9zrA

El 23.6.2010, a las 23:23 horas (vigilia de San Juan), en la estación de trenes de Rodalies (Cercanías) RENFE de Castelldefels Platja (Castelldefels, Barcelona), un convoy arrolló a un grupo numeroso de personas que, en aquellos momentos estaban cruzando las vías del ferrocarril. 12 personas fallecieron y 17 resultaron heridas de diversa consideración.

Las víctimas, viajeros de un tren de Cercanías que había llegado a la estación poco antes de que lo hiciera el convoy de media distancia que les arrolló, habían salido de sus vagones a cierta distancia de un paso subterráneo habilitado para pasar al otro lado del andén del ferrocarril, pero se habían dirigido a una pasarela superior, que estaba más próxima a ellos y que era la antigua salida de la estación, cuando se encontraron con que estaba inhabilitada y el paso cerrado por una cadena. Entonces algunos viajeros resolvieron fatalmente saltar a las vías para cruzarlas y acceder a la playa.

Como consecuencia del accidente, se iniciaron diligencias penales.

El 30.6.2010, el Juez entonces encargado de la instrucción del caso dictó un auto por el que se acordó el sobreseimiento libre de las diligencias previas. Las acusaciones particulares

interpusieron recurso de reforma y apelación contra dicho auto. Un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 10.1.2011, estimó el recurso, revocó el auto recurrido y ordenó la continuación de la instrucción a fin de practicar más diligencias. Las acusaciones particulares presentaron escrito en el que interesaban la imputación de las personas que ocupaban diversos cargos directivos en RENFE y ADIF en la fecha del accidente por 12 presuntos delitos o faltas de homicidio imprudente, así como por 17 delitos o faltas de lesiones imprudentes, a título de comisión por omisión. El Ministerio Fiscal, ADIF y RENFE se opusieron a lo interesado y presentaron escritos de alegación.

El AJPII nº1 Gavà, de 30.5.2012, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias previas (art. 641.1 LECrim) por "no darse (…) los requisitos que los tipos imprudentes exigen para apreciar su existencia" (FD 2.8) puesto que, "[d]el análisis de las actuaciones obrantes en autos no resulta la existencia de incumplimiento sustancial de la reglamentación y de las normas de cuidado a observar en el ámbito del tráfico ferroviario que permita afirmar la existencia de omisión de un deber de cuidado punible en la esfera penal" (FD 2.1).

En concreto, la Juez consideró probado que

a) "[E]l estado de mantenimiento técnico del tren (…) implicado en el siniestro [era] adecuado" (FD 2.2).

b) [E]l maquinista (…) cumplió en su conducción con todas las exigencias normativas al respecto" (circulación dentro de los límites de velocidad, llevaba encendidas las luces reglamentarias al momento de entrar en la estación, instante en que también accionó el claxon, y el resultado de las pruebas de alcoholemia resultó negativo) (FD 2.2).

c) [E]l apeadero de Castelldefels cumplía "los requisitos de seguridad y accesibilidad exigidos normativamente" (en concreto, había sido reformado en 2009 para adaptarse a las exigencias del RD 1544/2007, de manera que el cruce de pasajeros de un andén al otro mediante una pasarela superior fue sustituido por un paso subterráneo) (FD 2.3). Y,

d) "[L]as condiciones que en particular presentaba el apeadero en el momento de los hechos" eran igualmente adecuadas (iluminación suficiente, paso subterráneo accesible, "sin ningún obstáculo", y –extraordinariamente, por la mayor afluencia de personas en el apeadero con motivo de la noche de San Juan– tornos de salida de la estación abiertos, así como también los portones situados al lado de dichos tornos) (FD 2.3).

Finalmente, la Juez del caso afirmó:

"[N]o era previsible (…) que los pasajeros del tren de cercanías, incurriendo en una notoria negligencia y prescindiendo de las más elementales normas de cuidado, incumpliendo con lo previsto en la normativa aplicable, decidieran, sin buscar el paso habilitado al efecto [ya que "desde que el tren de cercanías abandonó la estación hasta que se produjo la entrada en el mismo del tren causante del siniestro transcurrieron únicamente 15 segundos"], pasar al otro andén cruzando directamente las vías, sin prever que por las mismas se podría acercar otro tren (…) (FD 2.6). "Siendo tal decisión de todo punto imprevisible", sus efectos "no [son] imputable[s] a las personas respecto de las cuales se pretende su imputación por las acusaciones particulares" (FD 2.7).

A continuación, se reproducen tres fotografías de la estación de Castelldefells Playa, donde ocurrió el accidente y otras tres de dos estaciones de ferrocarril suizas, Grindelwald e Interlaken-Ost. En las estaciones secundarias de la Confederación Helvética es frecuente que no haya ni pasos elevados ni subterráneos: los pasajeros esperan a que el empleado del ferrocarril que viaja con ellos en cada tren les indique el momento apropiado para cruzar los andenes.

El contraste entre España y Suiza sugiere una reflexión sobre los comportamientos apropiados en derecho: en ambos países, la gente, las infraestructuras y las normas –la cultura- son distintas, así, las reglas de derecho más apropiadas para evitar accidentes o reducir su número y disminuir su gravedad pueden analizarse habida cuenta de su interacción con aquellas y, en

particular, con la gente, con las personas (*people*) quienes, mejor o peor educadas, asumen un nivel de precauciones congenial con su entorno. La modificación de las reglas de derecho o de su interpretación posible puede llevar a modificar la infraestructura, el sistema de normas culturales o el comportamiento de la gente. La decisión sobre qué efecto es preferible –estaciones como la española o las suizas, por ejemplo- no es autoevidente.

Estación de ferrocarrils de Castelldefels

Der Bahnhof Grindelwald

Der Bahnhof Interlaken-Ost

1.1.2. Accidente de ferrocarril

STS, 1ª, 44/2010, de 18 de febrero:

El 19 de marzo de 1994, dos menores, de 15 y 16 años de edad, circulaban en un ciclomotor de una sola plaza. Su conductor, quien carecía de permiso de conducir, cruzó la vía del tren por un paso a nivel sin barreras ni semáforos, en A Rúa (Padrón, A Coruña), y un tren arrolló a ambos muchachos matándoles en el acto. A un lado del paso, había una señal descolorida; al otro, un poste de unos dos metros de altura con señales de atención al tren; pero en ninguno había señal, preceptiva, de stop. Los dos menores, vecinos del lugar, conocían el paso a nivel. En el momento del accidente el tren circulaba a 98 km/hora, la velocidad máxima permitida era de 100 km/hora y el convoy era visible aproximadamente a un kilómetro de distancia del lugar del accidente en línea recta. A unos 600 m. del paso a nivel existía la señal reglamentaria que ordena “silbar”.

Los padres y el hermano, respectivamente, de los dos fallecidos interpusieron sendas demandas contra Renfe y el maquinista del tren. Los padres y hermano de una de las víctimas solicitaron que "se declare la obligación de [Renfe] de dotar al paso a nivel e inmediaciones… de las medidas de seguridad, protección y advertencia a los usuarios…, necesarias para evitar riesgos en las personas y en las cosas, atendiendo a las circunstancias de la zona y en particular el cercamiento de la vía al paso por la población y dotación de barreras o mecanismos de obligada detención de vehículos y personas …" y que se condene a los demandados a pagar 90.361,45 euros a cada uno de los padres del fallecido y 60.240,96 euros al hermano, así como 553,48 euros por gastos funerarios. Los padres y el hermano de la otra víctima solicitaron una indemnización de 132.530,12 por el fallecimiento del menor, 90.361,45 euros por daño moral y 1.826,55 euros por gastos funerarios.

El JPI estimó sustancialmente la primera demanda: condenó a Renfe a "dotar el paso a nivel e inmediaciones sito en A Rua de las medidas de seguridad, protección y advertencia que sean necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas" y condenó a ambos demandados a pagar 144.821,15 euros a los padres, 18.807,93 euros al hermano, ambas cantidades en concepto de daño moral, y la cuantía reclamada por gastos funerarios. Asimismo, el JPI estimó sustancialmente la segunda demanda y condenó a ambos demandados a pagar las mismas cantidades en concepto de daño moral y la cuantía reclamada por gastos funerarios.

La Audiencia Provincial (AP) de A Coruña estimó el recurso de apelación de Renfe, revocó la SJPI y desestimó ambas demandas:

"Es obvio por demás que en principio la causa del accidente fue el grave descuido de las víctimas, que, con infracción de todas las normas de la prudencia y de la circulación viaria, se metieron literalmente debajo del tren; descuido relativamente explicable por la edad juvenil, pero no por ello prescindible e intrascendente cuando de la aplicación del Derecho se trata (…) no es posible atribuir a los demandados alguna de las omisiones concretas de las que derivar su responsabilidad en el accidente (…)"

"Pero ha sido objeto también de debate otra interesante cuestión: si existe responsabilidad de Renfe por no haber abordado ya la supresión de ese concreto paso a nivel, o, al menos, su reordenación para dotarlo de mejores medios de seguridad, como barreras o semibarreras. Es claro que la actual red viaria, con la existencia de pasos a nivel para cruzar la línea férrea, deriva de razones que en tiempos pretéritos los hicieron necesarios; sin que, por otra parte, creasen tan elevado riesgo como en la actualidad, al haber aumentado tanto la circulación de vehículos a motor que se ven obligados a cruzar por ellos. Pero en los tiempos presentes, con medios técnicos muy superiores, se ha impuesto la política conducente a la eliminación de tan peligrosos obstáculos viarios, que por unas u otras razones se han cobrado muchas vidas, como en el caso que nos ocupa (…) Responde a tal criterio el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Real Decreto 1211/90, de 28 setiembre), que en su artículo 235 contempla tanto lo relativo a nuevos pasos a nivel, que solo permite con carácter excepcional y por causas absolutamente justificadas, como la supresión de los actuales o en otro caso, para los subsistentes, la adopción de sistemas de seguridad y señalización más eficaces… Pero es de advertir que el accidente ocurrió el 19 de marzo de 1994, y que por ello el texto vigente era la primera redacción del artículo 235. A tenor de ella, en su apartado 4, "Los pasos a nivel que resulten subsistentes deberán contar con los sistemas de seguridad y señalización adecuados para garantizar su seguridad que, a tal efecto, se determinen por los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo y de Transportes, Turismo y Comunicaciones". Pues bien, estos sistemas de seguridad no se determinaron ministerialmente hasta la Orden de 1 de diciembre de 1994 (BOE de 14 del mismo mes), varios meses después de haber ocurrido el accidente objeto de este litigio. En ella se disponen las medidas de seguridad correspondientes a un paso a nivel como el de litis, que se califica de clase A, en el que ha de procederse a la instalación de la señalización que allí se hace constar (artículos 8 y 9). No cabría, pues, imputar a RENFE un retraso o dejadez en la aplicación de medidas de seguridad que se anunciaban en el Decreto de 1990, con remisión a lo que dispusiesen los Ministerios competentes, y que no se concretaron hasta después de ocurrido el accidente. Pero ha de tenerse muy en cuenta respecto a las medidas de señalización a instalar en la carretera o camino, que la norma, que se remite a las del Reglamento General de Circulación ya aludidas, al igual que éste, responsabiliza de aquéllas al

titular de tales vías (disposición adicional sexta). ... [E]s lo que ya establecía la Orden de 8 de mayo de 1982, vigente cuando el desdichado accidente ocurrió ... A RENFE solo correspondía entonces y ahora la señalización establecida para la vía férrea (FD. 4º).

Los actores de la primera demanda interpusieron recurso de casación que el TS desestimó:

"La "defectuosa señalización" del paso a nivel, admitida por la AP, no desempeñó papel relevante alguno en la determinación del nexo de causalidad, sino que, en expresión de la sentencia recurrida, la causa del accidente estuvo en "el grave descuido de las víctimas, que, con infracción de todas las normas de la prudencia y de la circulación viaria, se metieron literalmente debajo del tren" (FD. 3º).

En "Trenes"(InDret 1/2000, www.indret.com), un artículo publicado en el año 2000, Carlos Gómez Ligüerre y Pablo Salvador Coderch analizaron la jurisprudencia española de la época a la luz de la experiencia norteamericana, es decir, a la de una cultura industrial mucho más avanzada tecnológicamente que la española. En el artículo, se rememoraba el intento lúcido, brillante, pero finalmente fallido, de un magistrado legendario, William Wendell Holmes, Jr., de establecer una regla única para resolver todos los casos de arrollamiento en pasos a nivel sin barreras. Holmes propuso que, ante un paso a nivel, los conductores de automóviles habían de detener sus vehículos, salir de ellos, mirar a uno y otro lado de las vías y escuchar si se acercaba algún tren (***"Stop, look and listen"***). De no adoptar tales precauciones, opinaba, las víctimas o sus sucesores no podrían reclamar nada por el accidente sufrido. La historia, contada en *Trenes*, enseña que la regla duró pocos años y que, al cabo, los tribunales norteamericanos hubieron de recurrir a criterios más matizados. Probablemente, lo mismo ha sucedido con las propuestas sobre precauciones exigibles que Gómez y Salvador formularon en el artículo citado. El tiempo solo respeta aquello que ha creado.

1.1.3. Infracción de deberes de información / *Failure to warn*

STS, 3ª, de 25 de junio de 2010

El 7.6.1997, Natividad, una niña de 10 años de edad, fue vacunada en Castilla-La Mancha contra la meningitis con vacuna antimeningocócica A+C de polisacáridos (Mencevax A+C). Pocos años después en 2000, la administración sanitaria española tuvo conocimiento de que tal vacuna perdía efectividad al cabo de tres años. En el mismo año 2000, la administración inició una nueva campaña de vacunación contra al meningococo del serogrupo C para niños menores de seis años de edad, razón por la cual, no incluía a Natividad. El 8.4.2003, Natividad ingresó en el Hospital Bichat-Claude Bernard donde se le diagnosticó una meningitis C y le fueron amputados ambos pies. El 2.6.2003, fue trasladada al Hospital Saint Maurice de Paris, donde permaneció hasta el 27.6.2003. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Central de la Defensa de Madrid, donde estuvo ingresada hasta el 13.9.2003. En noviembre de 2003, la Comunidad de Castilla-La Mancha llevó a cabo otra campaña para vacunar a todos los menores de diecinueve años.

El 4.2.2004, la madre de la menor interpuso en nombre y representación de su hija una reclamación administrativa contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Castilla-La Mancha en la cual alegaba que la Administración había hecho dejación de funciones en el campo epidemiológico, al no haber realizado una campaña informativa adecuada sobre la persistencia de la meningitis, ni haber reaccionado ante la pérdida de efectividad de la vacuna Mencevax A+C. La reclamación fue desestimada por silencio administrativo. Posteriormente, por Sentencia de 22 de octubre de 2007, el TSJ de Castilla-La Mancha desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la reclamante.

En casación, el TS declaró el derecho de la recurrente a ser indemnizada en la cantidad de 800.000 euros:

"(…) aunque la incertidumbre es consustancial a la práctica de la medicina (…) los ciudadanos deben contar, frente a sus servicios públicos de la salud, con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica pone a disposición de las administraciones sanitarias", y "en la falta de información (…) radica la

dejación de funciones de la Administración (…) [El administrado no tiene] el deber de soportar el daño consistente en las lesiones y secuelas de por vida provocadas por la nefasta enfermedad" (FD 5º).

1.2. Fuentes primarias y secundarias/ *Primary and Secondary Sources*

En responsabilidad civil, la ley o la jurisprudencia establecen los casos y circunstancias en los cuales el demandado ha de ser condenado civilmente a reparar los daños causados por un suceso o acontecimiento dañoso que no debería haber ocurrido, que ha causado el demandado mismo y que el derecho puede considerar que ha de ser puesto a su cargo. Es muy difícil ofrecer una definición de la responsabilidad civil que sea, a la vez, omnicomprensiva, operativa y fecunda. Véase la siguiente, tomada de un libro clásico de un especialista norteamericano:

"A tort is a conduct that amounts to a legal wrong and that causes harm for which courts will impose civil liability" (Dan Dobbs, *The Law of Torts,* West, 2000)**.**

1.2.1. Legislación / *Statutes*

Hay muchas reglas de derecho español que establecen supuestos de responsabilidad civil o, más generalmente, de responsabilidad extracontractual. Las principales son las siguientes:

— Artículos 1902 y ss. del Código Civil de 1889.
— Artículos 109-125 del Código Penal de 1995.
— Artículos 139-146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
— Artículos 42-54 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
— Artículos 128 y ss. RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
— Artículo 123 del RDL 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Hoy en día, la ley y los reglamentos, el derecho legislado y regulatorio, ocupan un lugar creciente en la prevención de los accidentes y en la resolución de los conflictos a que su ocurrencia dan lugar. Aquí es importante destacar las diferencias básicas entre el derecho regulatorio de los accidentes y el derecho de daños creado y desarrollado por los tribunales:

—Las regulaciones miran al futuro, se establecen *ex ante*. En cambio, el derecho judicial de daños mira al pasado, se decide *ex post*.
—Las regulaciones suelen ser crecientemente detalladas, son conjuntos de reglas, no de principios o no solo de ellos. En cambio, el derecho de daños parte de principios o estándares que los tribunales concretan de modo mucho más fluido y, muchas veces, de modo intersticial.

Por ello, una pregunta capital del moderno derecho de daños es si la regulación detallada de una actividad cierra o clausura el sistema de modo tal que excluya toda pretensión adicional por derecho de daños o, por el contrario, el demandante pueda ejercitar una pretensión de responsabilidad civil además de los remedios previstos por la regulación específica del caso: es el tema de la "*preemption*", de la cuestión de si el derecho regulatorio cierra o no el paso a ulteriores reclamaciones por responsabilidad civil.

Un ejemplo: ¿cierra la regulación vigente en España sobre la disolución del matrimonio y sus consecuencias la posibilidad de que uno de los cónyuges ejercite una pretensión de

responsabilidad civil contra el otro y en cuyo fundamento alegue los daños morales que, presuntamente, le ha causado la infidelidad del demandado?

1.2.2. Jurisprudencia / *Case-law*

En España, el derecho de daños es fundamentalmente derecho jurisprudencial, *case-law*. Y lo es, entre otras razones, porque las disposiciones más importantes sobre la materia del derecho legislado son principios o estándares muy genéricos. Así, dos fuentes positivas básicas del derecho español de daños --el art. 1902 del Código Civil de 1889 y el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común— se formulan como principios (*standards*), no como reglas (*rules*). Por ello, su concreción y desarrollo quedan para la jurisprudencia y esta ha venido decidiendo constelaciones de casos que, muy aproximadamente, delimitan poco a poco grupos de supuestos de responsabilidad civil. Tales supuestos cambian con el tiempo y las circunstancias, como hemos visto que ocurre en los casos de accidentes de ferrocarril. El jurista que trabaja la interpretación del derecho a partir del estado de los conocimientos científicos y técnicos puede ofrecer criterios razonables sobre el sentido de las resoluciones que defiende. Sin embargo, no existe ninguna teoría que permita predecir y explicar la dinámica del derecho de daños y no existe por la misma razón por la cual no hay una ciencia de la Historia que nos permita predecir y explicar el devenir de una colectividad: el derecho y el derecho de la responsabilidad civil son partes de la Historia. Pero la razonabilidad del jurista es crucial a la hora de decidir, de nuevo por ejemplo, casos de accidentes de ferrocarril, si queremos encaminar a la colectividad hacia Castelldefells o hacia Interlaken. Siempre es importante que el jurista sepa hacer llegar a los tribunales y la colectividad misma el sentido último, las consecuencias de las decisiones que vayan a adoptar.

En derecho español, la Jurisprudencia en sentido estricto es solo la establecida por el Tribunal Supremo y, más concretamente, por cada una de sus Salas en asuntos de su competencia (*Spanish Supreme Court's Case-law*), pero la denominada jurisprudencia menor, las sentencias de las Audiencias Provinciales (*Spanish Courts of Appeals' Case-law*) son cada vez más importantes: en la actualidad, conocer cómo deciden las Audiencias las distintas constelaciones de casos es imprescindible en la buena práctica de cualquier abogado especializado en responsabilidad civil.

Dos buenas bases de datos de consulta:
— Westlaw Aranzadi (www.upf.edu/bibtic/recursos/bd/bd-a.html)
— CGPJ – CENDOJ (www.poderjudicial.es/jurisprudencia)

El equipo de investigadores que, en 1999, fundó InDret mantiene al día una selección de sentencias del Tribunal Supremo español sobre responsabilidad civil de los últimos años. Su contenido integra las páginas de este curso y ofrece un panorama de la jurisprudencia española reciente:

Pablo SALVADOR CODERCH, Sonia RAMOS GONZÁLEZ (Coords), Laura ALASCIO CARRASCO, Laura ALLUEVA AZNAR, Esther FARNÓS AMORÓS, Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, Ignacio MARÍN GARCÍA, Rosa MILÀ RAFEL, Magalí RIERA ROCA, Carlos Alb. RUIZ GARCÍA, "110 casos de derecho de daños (2004-2010)", *InDret* 4/2011 (http://www.indret.com/pdf/863_es.pdf).

1.2.3. Doctrina / *Secondary Literature or Secondary Sources*

Hay muchos buenos tratados, comentarios, monografías y artículos sobre responsabilidad civil. Los autores de este e-libro hemos seleccionado los siguientes, la mayor parte de los cuales versan sobre el derecho español, pero no todos, como lo lectores comprobarán:

— Hugo ACCIARRI, *Elementos de Análisis Económico del Derecho de Daños*, 1ª ed., Asociación latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía (ALACDE) & George Mason University, Law & Economics Center, Berkeley, California, 2009. Junto con el libro de

Bullard, dos de las más brillantes referencias latinoamericanas, utilísimas y usadas en las mejores universidades del cono sur por quienes ya son estudiantes de excelencia mundial.

— Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios al Código Civil*, 3ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2009 (Fernando PEÑA LÓPEZ, comentario a los arts. 1902 a 1910, pp. 2153-2171). Uno de los dos mejores comentarios globales al código civil español.
— Alfredo BULLARD, *Derecho y Economía. El Análisis Económico de las Instituciones Legales*, 2ª ed., Palestra Editores, Lima, 2006.
— Ana CAÑIZARES LASO/Pedro DE PABLO CONTRERAS/Javier ORDUÑA MORENO/Rosario VALPUESTA FERNÁNDEZ (Dirs.), *Código civil comentado*, Vol. 4, 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011 (Javier PLAZA PENADÉS, "Comentario al art. 1902", pp. 1454-1464; y Esther GÓMEZ CALLE, "Comentario al art. 1903", pp. 1464-1476). El otro.
— Robert D. COOTER/Thomas ULEN, *Law and Economics,* 6th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2011. Presentación asequible, muy meditada y muy bien escrita: una excelente introducción para estudiantes que no cursen doble grado.
— DEUTSCH/AHRENS, *Deliktsrecht*, 5. Aufl, Verlag Carl Heymanns Verlag, 2009 (buen libro de introdución).
— Simon DEAKIN, Angus JOHNSTON, Basil MARKESINIS, *Markesinis and Deakins' Tort Law*, 6th ed., Oxford University Press, Oxford, 2007. Obra británica de referencia.
— Luis DÍEZ-PICAZO, *Fundamentos de derecho civil patrimonial*, Tomo V, 1ª ed. Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011. Referencia española: da razón del pensamiento dominante.
— Richard A. EPSTEIN/Catherine M. SHARKEY, *Cases and Materials on Torts*, 10th edition, Aspen Publishers, , 2012. La vieja y sabia América de Richard Epstein se encuentra con la joven y brillante Caty Sharkey, ambos trabajan en la universidad más potente en derecho académico de daños. Al menos hoy.
— Michael FAURE, *Tort Law and Economics* (*Encyclopedia of Law and Economics*, Vol. 1, 2nd edition), Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) – Northampton, Massachussetts (USA), 2009. La enciclopedia.
— Massimo FRANZONI (Dir.), *Trattato della Responsabilità Civile* (Vol. 1: *L'illecito*, Vol 2: *Il danno risarcibile*), 2ª ed., Dott. A Giuffre – Editore, Milano, 2010.
— James A. HENDERSON/Richard N. PEARSON/Douglas A. KYSAR/John A. SICILIANO, *The Tort Process*, 7th edition, Aspen Publishers, New York, 2007. Tres generaciones de académicos de primer nivel suman sus fuerzas para producir un case-book extraordinario
— InDret. Revista para el análisis del derecho: www.indret.com. El origen de todo esto: un producto muy costoso, acaso de algún valor y gratis (para sus lectores). Editado y escrito por tres generaciones de civilistas.
— Hein KÖTZ/Gerhard WAGNER, *Deliktsrecht*, 11., neu bearbeitete Auflage, Verlag Vahlen, München, 2010. El mejor puente entre el derecho alemán, el *common law* y el moderno análisis del derecho de daños, escrito por dos especialistas de primer nivel y de distintas generaciones, un clásico. Comparte con los case-books angloamericanos un lenguaje admirable, pues está muy bien escrito.
— José Luis LACRUZ BERDEJO et. al., *Elementos de Derecho Civil II, Derecho de Obligaciones,* Vol. 2º, Contratos y Cuasicontratos. Delito y cuasidelito. 4ª ed., Dykinson, Madrid, 2009. Manual español de referencia.
— Thomas J. MICELI, *The Economic Approach to Law*, 2nd edition, Stanford University Press, Stanford, 2008 (óptima introducción analítica, indicada para estudiantes de doble grado).
— *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch* (Band 5: *Schuldrecht - Besonderer Teil III §§ 705 – 853, Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, Produkthaftungsgesetz*), 5. Auflage, C.H. Beck, 2009 (presentación clásica, panorama para práctica y academia).
— L. Fernando REGLERO CAMPOS (Coord), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 4ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2008. El testamento de un gran profesor, prematuramente desaparecido.
— Encarna ROCA TRÍAS/Mónica NAVARRO MICHEL, *Derecho de daños. Textos y materiales*, 6ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. La voz de profesoras de dos generaciones, una de ellas magistrada del Tribunal Supremo y, desde 2011, del Tribunal Constitucional.
— SCHWARZ/WANDT, *Gesetzliche Schuldverhältnisse – Deliktsrecht, Shadensrecht, Bereicherungsrecht, GoA*, 4. Auflage, Verlag Vahlen, 2011. Imprescindible para la formación de un académico versado en *Civil Law*: el derecho de daños en la primera potencia industrial y exportadora de Europa, un país cuyos sectores de actividad están intensamente regulados y que no se puede permitir inseguridad jurídica ni incertezas de

ningún tipo a la hora de delimitar las incumbencias de cada persona u organización en el marco de una división extrema y excelente del trabajo.

— Steven SHAVELL, *Foundations of Economic Analysis of Law*, 1st edition, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2004 (paradigma implacablemente neoclásico del análisis económico del derecho, sin casos).
— Geneviève VINEY, *Introduction a la responsabilité* (2008), *Les conditions de la responsabilité* (2006), *Les effets de la responsabilité* (2011), 3ème éd. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), (Collection Jacques GHESTIN [Dir.], *Traité de droit civil*).

1.3. Análisis económico del derecho / *Law and Economics*

La economía, la ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios (Paul Krugman/Robin Wells), puede aplicarse al análisis del derecho –como también pueden serlo la psicología, la ciencia política o la sociología- y, durante el último medio siglo, lo ha sido con mucho éxito y algunos fracasos -notablemente, algunos excesos-.

El análisis económico del derecho puede ser positivo o normativo.

El análisis positivo pregunta sobre las consecuencias económicas del establecimiento y aplicación de una regulación determinada, por ejemplo, ¿qué efectos tendría establecer una regla general de defecto en cuya virtud la velocidad máxima en vías urbanas no debe superar los treinta kilómetros por hora?

El análisis normativo pregunta sobre cuál es la mejor regla, de entre varias reales o posibles, en términos de eficiencia económica y, por ello, de entre las distintas alternativas razonablemente posibles en términos de limitación de velocidad en vías urbanas, considera preferible aquella que resulte más eficiente en términos de costes y beneficios sociales.

El análisis económico puede aplicarse al derecho de daños, al derecho de accidentes abordado con las técnicas de la responsabilidad civil, y parte de considerar las consecuencias probables, positivas y negativas, de las distintas actividades sociales cuyo desarrollo genera accidentes.

Thomas J. MICELI (*The Economic Approach to Law*, 2nd edition, Stanford University Press, Stanford, 2008), uno de los mejores analistas económicos del derecho, señala que el riesgo de causar algún daño es el subproducto inevitable de muchas –si no de todas- las actividades sociales globalmente beneficiosas. Y aunque, escribe, normalmente no podemos eliminar el riesgo sin suprimir de raíz la actividad de que se trate, deberíamos adoptar todas las medidas, justificadas en términos de costes y beneficios, para minimizar el riesgo: deberíamos, pues, invertir en reducción de riesgos cantidades crecientes de recursos hasta el punto en que un euro adicional empleado en evitar pérdidas derivadas de los accidentes solo consigue impedir accidentes estimados justamente en otro euro.

Cualquier sociedad avanzada dispone de muchos medios distintos, jurídicos y no jurídicos, para controlar los riesgos derivados de las actividades peligrosas –de casi todas-, pues, además de la responsabilidad civil, tales actividades pueden estar sujetas a regulaciones de seguridad, a impuestos, al derecho administrativo o, incluso, al derecho penal, además de estarlo a medidas físicas de seguridad o a tradiciones educativas y cívicas que nada tienen que ver con el derecho.

En todo caso, la esencia de la responsabilidad civil es la obligación potencial, asumida por el demandado, de reparar los daños causados a la víctima de un accidente y que esta o un allegado suyo, si la víctima falleció, reclama ante un tribunal de justicia.

1.4. El concepto, las clases de accidente, y las limitaciones del derecho de daños. La minimización de los costes sociales de los accidentes

1.4.1. El concepto y las clases de accidente

Accidente: suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas (DRAE).

A mishap, a mischance, especially one causing injury or death (Collins English Dictionary).

Clases de accidentes: la implosión de la distinción entre accidentes naturales y accidentes causados por conductas humanas

Tradicionalmente los accidentes pueden ser naturales o causados o cocausados por una conducta humana, individual o colectiva.

Ejemplos de accidentes naturales (*natural accidents, acts of God*) son los terremotos, como los de Haití y Chile, de 2010, o los maremotos (*tsunami*), como el de Japón en 2011. También los huracanes, ciclones, tormentas, inundaciones, incendios de origen natural. Los accidentes naturales no siempre son acontecimientos discretos, sino que, en ocasiones, son fenómenos que tienen lugar muy lentamente y cuyos efectos se manifiestan a lo largo de periodos muy dilatados de tiempo: así los denominados *Medieval Warm Period (950-1250*) o *The Little Ice Age, 16th-19th centuries.* Pero en estos últimos casos, la noción de accidente se difumina hasta desaparecer. Luego, no todos los accidentes naturales son catastróficos (Pablo SALVADOR CODERCH/Sonia RAMOS GONZÁLEZ/Rosa MILÁ RAFEL, "Catastrophic Damages: Liability and Insurance", in Karen B. BROWN/David V. SNYDER [Eds.], *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law*, 1st edition, Springer, New York, 2012, p. 85-103, esp. 90), sino que muchos de ellos dañan únicamente a una o a muy pocas víctimas, como la caída de un rayo o de un árbol.

Los accidentes causados por una conducta humana (*caused by human agency*) son tales como los de trabajo, los de tráfico, los iatrogénicos, los domésticos: en estas páginas nos centramos en los accidentes causados o agravados por conductas humanas.

La distinción entre accidentes naturales –*Acts of God*- y accidentes causados por los seres humanos está en crisis: 2008 fue el año en el cual, por primera vez en la historia de la Humanidad, más habitantes de la Tierra vivían en ciudades que en el campo. Ciertamente, el campo es una idealización que, al menos desde la Revolución Neolítica, desde la última glaciación, hace 10.000 años, cada vez ha tenido menos que ver con la Naturaleza, con el mundo silvestre, no humanizado. Tanto es así que, para muchos geólogos –rendidos a la geografía, una ciencia humana-, ya no vivimos en el Holoceno, la fase del Cuaternario posterior a la última Glaciación, sino estamos en pleno Antropoceno, en la Era del Hombre (Paul Crutzen y Eugene Stoermer).

Así, el terremoto de Haití, de 12 de enero de 2010, mató quizás a 200.000 personas, pero el poco posterior de Chile, de 27 de febrero de 2010, de mayor intensidad, a menos de 600: Chile estaba mucho mejor preparado que Haití para soportar la catástrofe. El Tsunami de Japón, de 11 de marzo de 2011, mató a casi 16.000 personas, pero su consecuencia más destacada culturalmente fue su efecto sobre la central nuclear de Fukushima Daiichi y sobre la política energética mundial de una generación. Para muchas personas, los accidentes naturales no existen. No es así, pero el jurista hará bien en apuntar a las posibilidades que la ciencia y la técnica ponen a nuestra disposición para prevenir un accidente y los costes de todo tipo de la prevención. Un ejemplo de libro es la susceptibilidad de algunas localidades del Sureste español a un terremoto: sabemos que se producirá, pero no estamos en condiciones de decir cuándo (véase la web del Servicio de Información Sísmica del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento).

1.4.2. Algunas limitaciones del derecho privado de daños

Otras distinciones en crisis son las que dividen al mundo en sistemas nacionales de derecho. Desde 2009, se discute sobre el concepto de límites, linderos o fronteras ecológicos del planeta (*environmental boundaries of the world*) que se construye sobre nueve categorías de problemas, algunas de las cuales, al menos, no reconocen fronteras políticas ni, por tanto, sistemas nacionales de derecho (cambio climático, acidificación de los océanos, desaparición de la capa de ozono, intervención en el ciclo del nitrógeno, roturación y urbanización crecientes, extinción, incremento de los polucionantes químicos y su creciente concentración en la atmósfera). Algunas de estas fronteras no son globales, pero otras lo son y todas obligan a poner de manifiesto las limitaciones del derecho de daños como derecho de los accidentes: tratados internacionales, políticas mundiales, derecho público y regulatorio, derecho sancionador, impulso del desarrollo tecnológico son instrumentos aparentemente mucho más eficaces para afrontar los retos del Antropoceno que el viejo derecho nacional de daños.

Sin embargo, el derecho de daños juega un rol esencial en tanto en cuanto constituye un instrumento de cambio del derecho mismo de los accidentes, es un motor de su dinámica: típicamente, los nuevos supuestos de responsabilidad civil impulsan cambios de legislación, las iniciativas descentralizadas de los abogados especializados en responsabilidad civil anuncian con frecuencia los cambios que han de llegar.

Así, los derechos de daños son fundamentalmente nacionales, pertenecen a sistemas estatales de derecho –aunque haya macrosistemas regionales armonizados de derecho de daños, como sucede con el derecho europeo de la responsabilidad civil del fabricante--.

Se trata de sistemas caracterizados por rasgos comunes: son, como acabamos de señalar, fundamentalmente nacionales, pero las herramientas analíticas utilizadas para su explicación y mejora son globales permitiendo una valoración también global de cada sistema nacional. En todos ellos, podemos preguntar sobre los costes y beneficios de la responsabilidad civil –que es muy costosa de aplicar-, sobre su contribución a mejorar la eficiencia, en sentido económico, de las conductas humanas, sobre la que puedan tener, psicosociológicamente, a corregir los sentimientos de maltrato, de trato injusto, que la causación de un daño pueda haber generado en sus víctimas o en la sociedad, sobre los efectos meramente distributivos de su aplicación, etc.

Luego, son sistemas basados en la aplicación privada del derecho, en el ejercicio de pretensiones resarcitorias por decisión de las víctimas de un daño o –si estas fallecieron- de sus herederos o allegados. Operan *ex post*, después de que el accidente y, por tanto, el daño hayan tenido lugar. Y su rasgo más característico consiste en que toda acción de daños en cualquier sistema de derecho consiste en el ejercicio judicial de una pretensión tendente a la reparación del daño o a su indemnización en dinero, dirigida contra el causante del daño, la persona, natural o jurídica, que ha de responder por aquel, o la compañía aseguradora de ambos.

1.4.3. La minimización de los costes sociales de los accidentes (Guido Calabresi, 1970; Steven Shavell, 2004) y las simplistas pero escasamente realistas asunciones iniciales de los modelos analíticos del moderno derecho de daños

Durante el último medio siglo la idea de que el derecho de daños puede contribuir, con otras ramas del derecho, a reducir y, específicamente, a minimizar los costes sociales de los accidentes ha ido a más. Aunque los sectores doctrinales más tradicionales del derecho civil español se aferran a la idea de que el derecho de la responsabilidad civil persigue principalmente compensar daños, nadie hasta ahora ha sido capaz de negar fundadamente que la compensación perfecta supone prevención óptima: la prevención de daños es la sombra de su compensación. Y es que a poco que se paren a pensar, cualquier sistema de reglas de responsabilidad civil que consiguiera que todos los casos de accidentes por los cuales alguien ha de responder se transigieran o litigaran con el resultado de que el demandante obtuviera una

compensación integral de los daños, prevendría óptimamente la ocurrencia potencial de tales daños: yo no voy a pagar un daño de 100 si tengo la certeza de que me van a condenar a pagar esa cantidad, pero *ex ante* puedo evitar el accidente invirtiendo 75 en precauciones (75< 100).

Al respecto, los modelos más sencillos del análisis económico parten de asunciones simples, escasamente realistas, pero heurísticamente muy fecundas, pues, en términos generales, las personas razonablemente bien informadas y que no estén trastornadas responden a los incentivos. Básicamente, los modelos parten de suponer que, primero, podemos identificar un nivel de precaución que minimiza el coste total de los accidentes para cada tipo de actividad (fabricar objetos, conducir automóviles, prestar servicios médico-sanitarios, etc.). El coste total incluye los costes privados, es decir, los que sufre la víctima, y los costes sociales, los que experimentan terceros.

En segundo lugar, los modelos asumen, también muy drásticamente, que los agentes sociales son neutrales al riesgo, que están perfectamente informados de las consecuencias de sus actos –o de sus omisiones- y que sus conductas individuales son la única causa de cada accidente, es decir, que las víctimas nada pudieron hacer para evitar el daño.

Asumen además que los individuos son económicamente racionales en el sentido de que responden a los incentivos de forma tal que su comportamiento se ajusta siempre al que resulta más eficiente, dada una regla de derecho que se les aplicará inexorablemente en todos y cada uno de los casos en que incurran en una conducta dañosa por la que hayan de responder.

Finalmente, se suele suponer que las reglas de derecho de daños objeto de análisis permiten conseguir una compensación perfecta de los accidentes, de modo tal que sus víctimas son compensadas de forma tan ajustada al daño sufrido que si, antes del accidente, fueran preguntadas sobre qué preferirían, si no sufrir el accidente o sufrirlo y ser indemnizados por ello, responderían que les daría igual.

A lo largo de este curso, veremos que ninguna de estas asunciones puede mantenerse incólume, pero, como en muchos experimentos, conviene comenzar pensando qué ocurrirá si los realizamos en el vacío. Luego, tiempo habrá para complicar las condiciones de partida. Pero, por muchas complicaciones que añadamos, nunca prescindiremos de la idea básica de que, a la larga, la gente responde a los incentivos.

Frente a las limitaciones del análisis moderno del derecho de daños, el análisis doctrinal tradicional insiste en la de que la responsabilidad civil pretende únicamente compensar íntegra o limitadamente daños causados, corrigiendo en su caso la injusticia generada por el daño mismo. Mas, como ya hemos señalado, si el derecho de daños en acción compensa adecuadamente, es decir, íntegramente, a todas las víctimas en todos los casos de causación de un daño por los que se haya de responder, también minimiza los costes de los accidentes de que se trate. Últimamente, el análisis tradicional admite la función preventiva del derecho de daños, pero solo como una consecuencia de hecho, no como una efecto normativo del derecho de la responsabilidad civil. La observación sobre la dualidad entre efectos de derecho y de hecho roza la metafísica. Mucho más relevante es otra distinta que relaciona el derecho de daños con una función correctiva, catártica, restauradora del orden jurídico y social alterado por el causante y responsable de los daños. Esta es mucho más digna de consideración que la anterior y apela a la psicología social, un punto de vista desconsiderado por el análisis económico neoclásico del derecho.

Sesión 2ª

1.5. Las cuatro grandes reglas de responsabilidad: no responsabilidad, dolo, culpa o negligencia y responsabilidad objetiva/*Basis: No Liability, Intentional Torts, Negligent Torts, and Strict Liability.* El límite de la responsabilidad absoluta

Como hemos visto en la Sesión 1ª, en responsabilidad civil, las circunstancias en las cuales el demandado ha de responder por los daños sufridos por la víctima son muy diversas y dependen de la regulación y la jurisprudencia aplicables al caso. Pero, en términos muy generales, hay cuatro grandes reglas de responsabilidad civil:

1.5.1. La regla de la ausencia de responsabilidad (*No liability*): sobre la libertad de actuar sin miedo a sus consecuencias dañinas para terceros

El estatuto más básico de una conducta dañina –pero más beneficiosa que dañina—es aquel según el cual su realización no comporta ningún deber de indemnizar a sus víctimas. Contra lo que a menudo se cree, la regla de la no responsabilidad es, afortunadamente, muy frecuente: las pérdidas se quedan donde se han producido; los daños, allí donde han tenido lugar.

Un soldado, jurista y juez norteamericano, Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841-1935) expresó muy gráficamente esta idea, en su obra *The Common Law* (1881):

"Sound policy lets the losses lie where they fall except where a special reason can be shown for interference".

Muchos siglos antes, el Derecho romano lo había hecho con óptimo laconismo:

"casum sentit dominus".

Y en España lo mismo ha escrito la dos veces magistrada Encarna Roca en la Introducción a la 6ª edición de *Derecho de Daños. Textos y Materiales* (en colaboración con Mónica Navarro):

"En este libro se parte de un principio general: la persona que sufre un daño está obligada a asumir sus consecuencias, excepto si existen razones jurídicas para trasladarlas a quien lo ha producido" (p. 15).

Si la regla aplicable es la de ausencia de responsabilidad por los propios actos, no hay indemnización por daños, las víctimas se lamen sus propias heridas –si sobreviven a ellas- y el mundo sigue su curso. La regla incentiva niveles máximos de precaución en las víctimas potenciales (para evitar sufrir el daño), pero también un nivel cero de precaución en los causantes potenciales de daños (pues no habrá de pechar con sus consecuencias). La regla parte de que, para tales o cuales conductas, es preferible un principio de libertad individual sin consideración a los daños que la actividad de que se trate puede causar a terceros:

- Alguno de ustedes estará, sin duda, resfriado, pero sus compañeros no tienen derecho a reclamar indemnización alguna si, por ello, se contagian, mucho menos a exigirle que se quede en su casa, en cuarentena, hasta que cure del resfriado (en cambio, si hubiera contraído la tuberculosis, una enfermedad grave, quizás podrían reclamar por el contagio sufrido si el primer enfermo no adoptó precaución alguna).

- Todos ustedes tienen que soportar que su vecino compre el diario o se conecte a la radio en i-Tunes que ustedes detestan, que se peine, deje de hacerlo o que se atilde como guste o, más opinablemente, que se vista o medio desvista como le plazca.

- En nuestro derecho, nadie tiene derecho a ser amado, es decir, nadie puede ejercitar una pretensión judicial –una pretensión indemnizatoria, en nuestro caso– porque otra persona se niega a quererle, a amarle: no hay derecho al amor aunque ello pueda causar el suicidio del desesperado amante [***The Sorrows of Young Werther*** (*Die Leiden des jungen Werthers*) una novela de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), publicada en 1774]. Más discutiblemente, nadie tiene derecho a seguir siendo amado, aunque algunos juristas defienden que la infidelidad matrimonial y sus consecuencias biológicas deberían dar lugar a una pretensión indemnizatoria a favor del cónyuge afligido por ella.

- Parecidamente, varios aficionados a la práctica del noble deporte del rugby pueden decidir fundar un club deportivo, contratar un seguro de daños y comprometerse a no obligarse a responder recíprocamente por las lesiones causadas en el juego. En general y en derecho de contratos, las partes pueden excluir limitadamente su responsabilidad por accidentes. A cambio de ello, la ley puede exigirles que contraten un seguro obligatorio de accidentes y, en todo, caso prohíbe la exclusión de responsabilidad por daños causados dolosa, intencionadamente, o acaso también los causados por negligencia muy grave, rayana en el dolo.

- Tampoco responden los padres ante un hijo suyo por el hecho de haberle traído al mundo en condiciones tales que el hijo dice luego que preferiría no haber nacido -o alguien lo dice por él, una asociación o una fundación, por ejemplo-. El derecho de familia obliga a los padres a cuidar al hijo precisado de ayuda, pero no concede a éste una pretensión de daños contra aquéllos. El derecho de daños se niega a comparar una vida dura, acaso invivible para muchos, con el vacío absoluto del nihilismo. Pero incluso esto también resulta polémico para algunas personas que se niegan a traer hijos a este mundo, por no tener que convivir con seres temporalmente heterónomos y absolutamente dependientes, al tiempo que defienden que quienes lo hagan, respondan por ello en casos como el presentado aquí.

- La competencia, sumada al desarrollo tecnológico, es, literalmente, destrucción creadora: las tabletas han arrasado las librerías tradicionales del mismo modo que la bombilla de Edison acabó con las cererías y el motor de explosión con las caballerías, o que LED está ahora acabando con las bombillas incandescentes y el motor eléctrico pueda acabar desplazando al de explosión. Pero competencia no es competencia desleal. Es, simplemente, competencia. Causa daños, causa muchos más beneficios que daños, disloca comunidades, acaba con estilos de vida cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, pero, en una sociedad abierta, no impide que una comunidad resuelva libremente vivir al margen del desarrollo tecnológico y de la competencia misma (un claustro monástico, una comunidad de Amish, otra neorrural, etc.), eso también, de modo mucho más sencillo y probablemente menos rico que el del resto de los consociados.

- En general, el ejercicio legítimo de cualesquiera derechos fundamentales puede originar y, de hecho, origina daños, pero son daños por los cuales el causante no habrá de responder. Una madre atea puede llegar a precisar asistencia psicológica, incluso a enfermar después de que su hijo entre en religión y un padre puede pasar por lo mismo o peor porque su hijo deja el oficio paterno, aborrece la ideología de los abuelos o abandona el país que les vio nacer a todos. Pero, afortunadamente, es ley de vida. Igualmente, mis vecinos pueden comprar los diarios, ver las películas o ser socios de los clubes que detesto, practicar la religión, educar a sus hijos, o votar de los modos más alejados a aquellos que considero apropiados para hacer real mi idea del bien común. Y así sucesivamente: no hay responsabilidad.

STS, 1ª, 270/2006, de 9 de marzo. Asunción de riesgo en la práctica deportiva.

El 16.11.1991, Luis Manuel, quien jugaba a golf en el "Club de Golf Terramar" de Sitges, falleció tras recibir el impacto de una pelota lanzada por Ismael, que se encontraba en una calle distinta

y separada de la de la víctima por una arboleda que impedía a ambos jugadores verse. El lanzamiento en cuestión había sido técnicamente incorrecto a causa del viento que soplaba en la zona.

Lucía, viuda del fallecido, en su nombre y en el de sus hijos menores, demandó a Ismael, al "Club de Golf Terramar", a "La Estrella S.A. de Seguros" y a "Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros", y solicitó una indemnización de 281.237 € de las tres primeras y de 1.803 € de la cuarta.

El JPI nº 2 de Vilanova i la Geltrú (22.5.1996) estimó en parte la demanda y condenó al pago de 111.908 €, con el límite de 1.803 € para "Plus Ultra Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros". La AP de Barcelona (Sección 15ª, 12.5.1999) estimó los recursos de "Club de Golf Terramar", "La Estrella S.A. de Seguros" e Ismael, a quienes absolvió.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por Lucía:

"La idea del riesgo, fundada en la explotación de actividades, industrias, instrumentos o materiales peligrosos, y en los beneficios que a través de ello se obtienen, en modo alguno puede trasladarse a la práctica deportiva, no organizativa, para fundamentar un régimen de responsabilidad distinto del de la culpa. Se asume el riesgo desde la idea de que se conoce y se participa de él y de que el jugador es consciente de que no existe en el desarrollo de una buena práctica deportiva, más allá de lo que impone la actividad en concreto, porque confía en la actuación de los demás" (F.D. 3º).

Así, la regla de no responsabilidad consigue básicamente dos cosas: potencia la libertad individual o colectiva por el procedimiento de demarcar o fijar los límites de las actividades por cuyo desarrollo y consecuencias no se habrá de responder, y ahorra de paso los costes de compensar accidentes, caso por caso, por responsabilidad civil, que es una institución jurídica muy cara de gestionar (típicamente por cada euro gastado en un caso litigado y ganado por el demandante, la mitad, cincuenta céntimos, se quedan por el camino).

Su contraria, una regla de responsabilidad absoluta y universal, por todos los daños derivados de la convivencia, del roce social, nos arruinaría a todos, nos paralizaría y la sociedad colapsaría en pocos años. Nadie defiende seriamente semejante totalitarismo del derecho de daños. No existe tal regla en ningún ordenamiento del mundo. Asombrosamente, muchos la piden. Sin pensar.

1.5.2. La causación dolosa, intencional, de daños

Es el caso más grave y, desde luego, es difícil encontrar un supuesto de causación intencional de daños, sobre todo si tiene como consecuencia la muerte o las lesiones de la víctima, que no constituya un delito o una falta tipificados por el Código Penal, además de ser un ilícito civil. Pero, en todo caso, junto con la responsabilidad penal surgirá la civil, la cual, con independencia de la anterior, obligará al imputado o a las personas de quienes dependiera a reparar los daños causados.

El dolo es grave en todos los sistemas jurídicos históricos y contemporáneos y es intuitivo que así sea:

- La probabilidad de causar dolosamente un daño suele ser mayor que la de causar el mismo tipo de daño con una conducta similar pero simplemente descuidada o negligente.

- Luego, el causante doloso de daños destruye riqueza dos veces: cuando se hace con el instrumento dañino y cuando lo usa.

- Finalmente, la psicología explica bien por qué los miembros de casi cualquier sociedad reaccionan de manera mucho más intensamente hostil contra quienes les causan daños de intento, a sabiendas y, a menudo, con la precisa voluntad de hacer daño. En el fondo, el principio básico de justicia correctiva, de retribución, en cuya virtud quien ha causado un daño -y sobre

todo, quien lo ha causado a ciencia y conciencia-- ha de pagar por ello está presente en todas la culturas históricas y contemporáneas (Neil VIDMAR, "Retribution and Revenge", en Joseph SANDERS/V. Lee HAMILTON [Eds.], *Handbook of Justice Research in Law*, reprint of 1st ed. 2001, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2010). El reto más serio al análisis económico del derecho de daños proviene de la psicología y de la psicología social, que muestran tanto que la conducta humana no siempre es económicamente racional como que la revancha, el rencor y el resentimiento forman parte de la condición humana. Otra cosa es que, paradójicamente, castigar pueda ser mucho más costoso para la víctima que perdonar y olvidar (Kevin M. CARLSMITH/Daniel T. GILBERT/Timothy T. WILSON, "The Paradoxical Consequences of Revenge", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 95, No. 6, 2008, p. 1316–1324).

1.5.3. La regla de la negligencia

La causación de daños por culpa o negligencia, por descuido más o menos grave, es decir, por no haber puesto en práctica, al desarrollar tal o cual actividad, las precauciones razonablemente exigibles, es el supuesto de partida de nuestro sistema jurídico en derecho privado: todos estamos sujetos a deberes de cuidado, de precaución, y si al llevar a cabo una actividad los infringimos, habremos de responder civilmente por los daños causados, es decir, habremos de repararlos, normalmente, indemnizando al demandante.

Además de definirse como infracción de deberes de cuidado, la negligencia puede caracterizarse como creación o incremento irrazonable de riesgos: toda actividad humana comporta riesgos –si estoy resfriado y salgo de casa puedo contagiar a las personas que se acerquen a mí-, pero la mayor parte de los riesgos normalmente asociados a una conducta son riesgos permitidos –ni la ley ni los tribunales me obligan a quedarme encerrado en casa por un simple resfriado-. Mi responsabilidad comienza allí donde el nivel razonable, socialmente admisible, económicamente sostenible, psicológicamente tolerable, éticamente soportable de riesgos sobrepasa el umbral de los riesgos permitidos –si soy un médico internista y he de trabajar en una unidad de cuidados intensivos, tal vez deba abstenerme de acudir a mi hospital si estoy muy constipado; si soy seropositivo de VIH, habré de abstenerme de tener contactos sexuales sin protección adecuada-.

La regla de la responsabilidad por culpa o negligencia está presupuesta en el art. 1902 del Código Civil, pero no está definida allí.

En el *Common Law,* los elementos del *tort* de la *Negligence* son cuatro:

1) Infracción de un deber de precaución o cuidado (*Breach of a duty of care*), es decir, de un deber impuesto por la ley, en sentido amplio, o por estándares sociales de razonabilidad ("deberes del tráfico" atendidas las circunstancias, de acuerdo con el criterio de un tercero, observador razonable). O, si se prefiere: creación o incrementos irrazonables de un riesgo de causar un daño.

La idea, escribe Shavell, es "that an injurer is held liable for the accident losses he causes only if he was negligent, that is only if his level of care was less than a level called due care that the courts specify" (*Foundations*, p. 180).

2) Daño, causado a los bienes sobre los cuales el demandante tiene algún derecho de propiedad o similar (*property harm*); o daño causado a su persona: muerte (*wrongful death*, en cuyo caso el demandante no será obviamente la víctima), daño corporal (*bodily injury*), pero también daños morales (*pain and suffering*); también daños puramente económicos (*economic losses*), es decir, no derivados de un daño personal o material, pero solo en algunos casos.

3) Causalidad, de hecho (*cause of fact*) y de Derecho (*proximate causation, scope of liability*). Relación entre la causa, la conducta del demandado, y el efecto, el daño sufrido por la víctima. Suele seguirse el test de la *condicio sine qua non, But-For test*, modulado por criterios de causalidad jurídica: de no haber sido por la conducta del demandado su víctima no habría sufrido el daño causado. Mas, como veremos, el *test* es muy burdo.

Una buena definición de negligencia se encuentra en el ***§ 3 Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm*** (2010), del *American Law Institute* (ALI):

"A person acts negligently if the person does not exercise reasonable care under all the circumstances. Primary factors to consider in ascertaining whether the person's conduct lacks reasonable care are the foreseeable likelihood that the person's conduct will result in harm, the foreseeable severity of any harm that may ensue, and the burden of precautions to eliminate or reduce the risk of harm".

La regla de la negligencia incentiva precaución adecuada en el agente de la actividad arriesgada, peligrosa, pero ninguna en su víctima potencial (si el daño que puede sufrir es compensable, reparable: muchos no lo son y sus víctimas potenciales tratan por ello de evitar sufrirlos).

La regla de la negligencia simple mira solo al causante potencial de daños, al demandado, no a su víctima potencial, al demandante ni a su conducta. La unilateralidad de la regla de la negligencia, su falta de consideración al comportamiento de la víctima potencial no es, por definición, problema alguno en la causación precisamente unilateral de daños, es decir, en un acontencimiento dañoso tal que la víctima nada pudo hacer por evitar o paliar el daño causado.

Así, un ejemplo posible de negligencia médica (*medical malpractice*) –aunque se discutió en el caso- es el planteado y resuelto por la **STS, 1ª, 1152/2002, de 29 de noviembre**: el cirujano demandado había intervenido quirúrgicamente, en diciembre de 1974, a un hombre de 34 años de edad para extirparle un tumor en su espina dorsal. Durante la operación, el cirujano dejó olvidada una gasa alrededor de la columna lumbar del paciente y, por ello, hubo de intervenirle de nuevo tres meses más tarde para retirarla. Con posteridad a esta segunda operación, el paciente presentó unas secuelas irreversibles que dieron lugar a su incapacidad permanente y demandó al cirujano una indemnización de 240.000 euros.

Otro caso, esta vez, absolutamente claro, de negligencia unilateral es el que resolvió la **STS, 1ª, 813/1997, de 26 de septiembre**, que trataremos al inicio de la sesión 3ª: la víctima, una mujer de edad madura, se había sometido, a principios de año 1984, a una operación de extirpación de un quiste ovárico en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Un tornillo minúsculo (4x3 mm.) se soltó de uno de los aparatos empleados durante la intervención, pero ni el el cirujano ni sus ayudantes se percataron de ello. Años después, la presencia del tornillo en el abdomen de la víctima fue detectada casualmente con ocasión de unas radiografías practicadas a la paciente con motivo de un accidente doméstico. En junio de 1987, operaron de nuevo a la actora para retirarle el tornillo que había acabado por adherirse a su útero, por lo que fue preciso practicarle una histerectomía. La víctima demandó al cirujano de la primera intervención y al Instituto Nacional de Salud (INSALUD) del que dependía. En la demanda solicitaba una indemnización de 60.000 euros, que le fueron concedidas por la primera instancia. La Audiencia Provincial de Zaragoza y el Tribunal Supremo desestimaron el recurso presentado por el INSALUD.

La **STS, 1ª, 340/2011, de 20 de mayo** recoge la doctrina jurisprudencial según la cual la responsabilidad civil del médico es en todo caso por negligencia: el 30.6.2005, Agustina, de 52 años, fue intervenida en la Clínica Clideba (Badajoz) de artrodesis instrumentalizada lumbar L4-L5 con tornillos pediculares y prótesis espaciadora intersomáticas por presentar espondilolistesis L4-L5 estenosis del canal L4-L5 y hernia foraminal L5-S1. Tras dicha intervención, se detectó la existencia de un sangrado abdominal precisándose el traslado de la paciente al Hospital Infanta Cristina, donde se procedió a ligar la arteria hipogástrica y al lavado de la cavidad. El 11.7.2005, Agustina fue reintervenida quirúrgicamente de sigma, pero falleció el 4.8.2005. La causa de la muerte fue el shock séptico inducido por la ligadura de la arteria mesentérica inferior, que, a su vez, había provocado una falta de riego y consiguiente necrosis isquémica del sigma del paciente y posterior sepsis al perforarse el sigma con desalojo de material fecal de la propia paciente.

Gaspar y sus cinco hijos, Maximino, Vicente, Abelardo, Zaira y Daniela (marido e hijos de Agustina) demandaron a Eugenio (neurocirujano), a la Compañía de Seguros Agrupación

Mutual Aseguradora (AMA) y a la Compañía de Seguros Caser Salud, en reclamación de la suma de 525.000 euros.

El JPI nº1 de Badajoz (28.5.2007) estimó en parte la demanda y condenó a la Compañía de Seguros Caser Salud al pago de 46.583,47€ a Gaspar, 7.763,91€ a Daniela y 3.881,95€ al resto de los demandantes.

La AP de Badajoz (Sección 2ª, 16.11.2007) desestimó sendos recursos de apelación interpuestos por Gaspar y sus cinco hijos y la Compañía de Seguros Caser Salud.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por los actores:

"La obligación del médico es de medios y no de resultados y estos medios que se deben poner a disposición del paciente se deben valorar no sólo en función de la economía del contrato de prestación de servicios médico-sanitarios sino en razón a los que derivan de esta relación y conoce la paciente, sin que sea posible cuestionar la actuación médico-sanitaria fundándose en la evolución posterior de la misma, lo que se conoce como la prohibición de regreso, para responsabilizar al médico de la materialización de un riesgo excepcional del que había sido previamente informada la paciente, que hacía innecesarios más medios de los que se disponían en esos momentos en una previsión lógica y ponderada de la intervención quirúrgica llevada a cabo." (FD 2º). Además, "[…] la responsabilidad fundada en la Ley de Consumidores y Usuarios no afecta a los actos médicos propiamente dichos, dado que es inherente a los mismos la aplicación de criterios de responsabilidad fundados en la negligencia por incumplimiento de la *lex artis ad hoc*. Por consiguiente, la responsabilidad establecida por la legislación de consumidores únicamente es aplicable en relación con los aspectos organizativos o de prestación de servicios sanitarios." (FD 3º)

Adelantemos que la regla de responsabilidad por negligencia permite controlar bien la calidad de la actividad, pero no su cantidad, el nivel de la actividad misma. Baste hoy con dejar dicho que la regla de la negligencia solo funciona bien si su contenido captura todas las dimensiones de la precaución (la calidad exigible de la actividad, pero también su nivel o cantidad, por ejemplo). Dicho sea a modo de ejemplo: un cirujano precavido interviene a sus pacientes, de acuerdo con las reglas de la profesión médica, la *lex artis*, pero no trabaja 24 horas seguidas sino que descansa entre operación y operación.

Sobre el concepto económico de negligencia en *United States v. Carroll Towing Co.* (159 F2d Cr. 1947), el caso de derecho de daños más famoso del siglo XX, véase el apartado 2.2.3.

1.5.4. La regla de la responsabilidad objetiva

El tercer gran supuesto de responsabilidad civil es la denominada responsabilidad objetiva o por riesgo, que cubre los casos en los cuales el demandado responde por los daños que ha causado simplemente por haberlo hecho aunque no haya habido ningún género de culpa o negligencia –ningún incremento irrazonable de riesgos o ninguna infracción de deberes de cuidado--.

En el derecho comparado de los países tecnológica y económicamente avanzados, el criterio más común en esta materia es que la responsabilidad objetiva requiere una decisión legal que la establezca o una jurisprudencia que la justifique sostenidamente. En el derecho español, la responsabilidad objetiva no es la regla general de defecto de llegada en derecho privado – lo es la responsabilidad por culpa, art. 1902 CC—, pero, por razones históricas asociadas con la pobreza endémica de nuestro país y la influencia del derecho de la expropiación forzosa, es el principio general del cual partió el legislador administrativo al establecer la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, art. 139 L. 30/1992. Sin embargo, el sistema es impracticable –por ejemplo, no se puede aplicar a los casos de responsabilidad por omisión— y en la vida legal cotidiana, las soluciones a las que llega la Sala 3ª del Tribunal Supremo (que parte de un estándar de responsabilidad objetiva) no son muy distintas de aquellas adoptadas por su Sala 1ª (que lo hace de otro de negligencia): dicho en términos aproximados, sería

contrario al buen sentido que el paciente de una clínica privada dispusiera de una pretensión por daños culposos mientras que el de un hospital público tuviera una pretensión por responsabilidad objetiva; o que el alumno de una escuela privada estuviera sujeto a un régimen distinto al de una escuela pública. Tiempo habrá de discutir esta cuestión, pero aquí bastará con dejar apuntado que los regímenes de responsabilidad han de establecerse, en su caso, por sectores o tipos de actividad, no por la condición, pública o privada, de quienes la realizan. Con todas las salvedades que correspondan, el principio general es que una actividad que pueden llevar a cabo tanto agentes públicos como privados ha de estar sujeta a un mismo régimen de responsabilidad por daños. A igualdad de actividad corresponde igualdad de estándar de responsabilidad.

De acuerdo con la regla de la responsabilidad objetiva, los agentes sociales responden por todos los daños que causan aunque no hayan incurrido en culpa o negligencia alguna: es responsabilidad por mera causación de daños, por creación de un riesgo que, en el caso, se concreta en un daño sufrido por un tercero.

La responsabilidad objetiva se llama, en inglés, *strict liability*: "injurers must pay for all accidents losses that they cause" (Shavell, *Foundations*, p. 179).Los alemanes hablan de *Gefährdungshaftung,* responsabilidad por riesgo. Y los italianos de *responsabilità per rischio*. En España, algunos autores escriben "responsabilidad objetiva" y otros "responsabilidad por riesgo". En este e-libro se sigue la primera convención.

La regla de la responsabilidad objetiva incentiva a los causantes potenciales de daños a adoptar los niveles requeridos de precaución, pero no incentiva a sus víctimas potenciales a adoptar ningún género de cuidado (siempre que los daños puedan ser reparados sin demasiados problemas, muchos no pueden serlo: solo se muere una vez, por ejemplo). Asimismo, la responsabilidad objetiva permite controlar no sólo la calidad de la precaución de los agentes de actividad, sino también su nivel mismo de actividad, también la cantidad, por tanto.

En derecho privado español, la responsabilidad objetiva no es la regla general, sino que requiere mandato legal, al menos en principio:

- Accidentes de circulación: Real Decreto Legislativo 8/2004**,** de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

- Administraciones públicas: arts. 139 y ss. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Animales: art. 1905 CC.

- Caza: art. 33.5 Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza

- Cosas que se arrojen o caigan de una casa: art. 1910 CC

- Energía nuclear: art. 45 Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.

- Medio ambiente: Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

- Navegación aérea: art. 120 Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea

- Productos defectuosos: Art. 1 de la Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por los productos defectuosos; arts. 128 y ss. RDL 1/1007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

- Responsabilidad del propietario por los humos excesivos nocivos para las personas o las propiedades y caída de árboles colocados en sitios de tránsito: art. 1908. 2º y 3º CC.

- Servicios: arts. 147-148 RDL 1/2007

STS, 1ª, 581/2007, de 28 de mayo. Accidente en helicóptero

José Augusto trabajaba como retén de incendios forestales para "TRAGSA", sociedad que había contratado con "HELICSA" los medios aéreos para la campaña 1991-92. El 18.9.1992, a causa de una tormenta, el helicóptero que transportaba a José Augusto se vio afectado por una turbulencia, chocó contra la ladera de una montaña y se incendió. Como consecuencia del accidente, José Augusto resultó herido y sufrió una incapacidad permanente total.

José Augusto demandó a "HELICSA" y a su aseguradora, "Allianz", en solicitud de una indemnización de 135.040,03 €.

El JPI de Purchena (23.9.1998) estimó la demanda. La AP de Almería (Sección 2ª, 31.3.2000) estimó en parte el recurso de apelación de los demandados, condenándoles a pagar 18.030,36 €.

El TS estimó en parte el recurso de casación interpuesto por José Augusto e incrementó el importe de la indemnización a 21.035.42 €. Si bien el accidente aéreo constituyó un caso fortuito, sostuvo el Tribunal, el transportista está sujeto a un régimen de responsabilidad objetiva con limitación del quantum indemnizatorio que no admite moderación alguna por los tribunales (art. 120 Ley de Navegación Aérea).

STS, 1ª, 1243/2007, de 4 de diciembre. Caída de una maceta desde el quinto piso de un edificio

El 21.7.1989, una mujer de 65 años de edad, falleció como consecuencia de ser golpeada en la cabeza por una maceta que, durante un fuerte temporal de viento, cayó desde el quinto piso de un inmueble de Madrid. La propietaria había arrendado el inmueble a Carina y tenía contratado un seguro multirriesgo de comunidades de propietarios con "AGF Unión Fénix, S.A.".

Bernardo, viudo de la fallecida, demandó a Romeo, Luis Enrique y Lourdes, viudo e hijos de la propietaria del piso, "AGF Unión Fénix, S.A." y Carina, arrendataria del piso, y solicitó una indemnización de 90.151,82 €.

El JPI núm. 58 de Madrid (11.7.1997) estimó en parte la demanda, condenó a Carina a pagar 48.080,97 € y absolvió al resto de demandados. La AP de Madrid (Sección 13ª, 12.7.2000) desestimó el recurso de apelación interpuesto por Carina y estimó el de Bernardo en el sentido de condenar a todos los demandados a pagar 60.101,21 €.

El TS estimó los recursos de casación interpuestos por Romeo, Luis Enrique, Lourdes y la aseguradora, a quienes absolvió. La propietaria no incurrió en negligencia por no haber advertido a la inquilina del peligro que representaban las macetas, pues ello supone "(...) la imposición al propietario-arrendador de un exacerbado deber de vigilancia o supervisión en la conducta del inquilino" (FD 2º).

1.6. Tipos de daño/*Types of Harm*

1.6.1. Análisis doctrinal/*Doctrinal Analysis*

En principio, la existencia de un daño actual es condición necesaria de responsabilidad: sin aquel no hay esta. En ausencia de daños actuales, pero ante la probabilidad de causarlos, el demandante puede disponer de acciones negatorias, de cesación y abstención de la actividad amenazante de causar daños (incluso de acciones tendentes a indemnizar al afectado por los costes de los chequeos y pruebas analíticas, periódicas para descartar la contración de la enfermedad), pero no de una acción de daños en sentido estricto. Hay excepciones, pero las

veremos más adelante (pérdida de oportunidad, *loss of chance*). El paciente expuesto a una sustancia tóxica o radioactiva que, estadísticamente, sabe que la probabilidad de contraer tal o cual enfermedad ha pasado del 0,0001% al 0,001% no tiene una acción por el 0,001 % de los daños probables.

Ahora bien, qué consecuencias se consideran dañinas es una cuestión de política jurídica –y económica, social, etc.- cuyo alcance depende de la intensidad de los deberes de precaución que se resuelva establecer, de los riesgos que se quieran prevenir.

Un buen punto de partida para abordar esta cuestión es tener en cuenta un núcleo claro de daños sencillos de identificar y, solo luego, el halo de posibles daños que rodea a los primeros, pero que son mucho más difíciles de estimar y probar –mucho más costoso de establecer, mucho más susceptible de error o de engaño sobre su realidad y cuantía-.

Así:

- Los **daños corporales** causados por un trauma externo son fáciles de determinar y suelen estar incluidos sin más en el ámbito de daños resarcibles. En cambio, los daños psicológicos, lo que los angloamericanos denominan *"pain and suffering"* o los alemanes llaman *"Schmerzengeld",* el daño o sufrimiento originados por el dolor de una herida, por la pérdida de un ser querido o por la destrucción de un bien son mucho más difíciles de determinar y, consecuentemente, mucho más fáciles de exagerar. Es normal, pues que la indemnizabilidad de los segundos sea menos fácil de admitir que la de los primeros.

- Los **daños a la propiedad** o a cualquier bien sobre el cual el demandante tenga un derecho subjetivo resultan también fácilmente identificables: una casa se incendia, un automóvil es destruido o gravemente dañado en un accidente. Pero la pérdida puramente económica –en inglés *"pure economic loss"-,* es decir, la pérdida o reducción de las ventajas económicas a que da normalmente lugar la explotación de un bien, o la prestación de un servicio es mucho más delicuescente y difícil de indemnizar: el demandante no causó ningún daño en mi establecimiento de restauración, pero sufrió un accidente en el túnel que permite acceder al pueblo en el que está situado y, durante todo el tiempo de interrupción del tráfico, el giro y tráfico del establecimiento se redujo considerablemente. En términos técnicos suele definirse el daño puramente económico como aquel que no está asociado a la producción de un daño material o físico, o –si es a las personas- corporal.

Dobbs resume bien el estado de la cuestión para el *common law* norteamericano y Ward Farnworth recoge el concepto más general de pérdida puramente económica:

"Actual damage or injury is a necessary element of tort liability (for negligence). What qualifies as actionable damage is a question of policy largely defined by the duty rules considered in the 5th chapter:

- While **bodily injury** from external trauma is categorically included, liability for mental distress is more hedged, depending on whether it results from an external injury or mere mental processes.

- **Property damage** is widely conceived, embracing any interference which diminishes the value of the object. Purely economic loss, -or loss not resulting neither from propoerty damage,nor from personal injury- however, is actionable only under limited controlled conditions.

  For merely threatened harm, an injunction but no claim for damages will lie. In other words, merely creating a risk of injury is not actionable; injury must have become actual. And, consequently, no cause of action accrues until damage has occurred.

  But what precisely qualifies as damage in cases of bodily injury or property damage, and when does it occur as to start the limitation period running? Asbestosis often remains undiagnosed for many years after exposure, yet the injury is evidently deemed to occur as soon as a lesion would have been discoverable by x-ray (...)"

Restatement of the Law Third, Torts: Liability for Economic Harm (Tentative Draft Tentantive Draft No. 1, April 4, 2011): "Pecuniary loss is pecuniary damage not arising from injury to theplainiff's person or from physical harm to the plaintiff's property".

El análisis doctrinal tradicional del derecho de daños se adecua razonablemente a los accidentes discretos, casuales o negligentes, que afectan a una persona o a un número reducido de ellas y que provocan un resultado instantáneo o evaluable al cabo de algún –poco tiempo-: la destrucción de un bien mueble o inmueble, la causación de la muerte de un peatón, la causación de heridas que sanan al cabo de algún tiempo o que dejan secuelas que pueden evaluarse sin demasiada complejidad.

Pero el análisis tradicional y el derecho mismo de daños funcionan muy limitadamente en los casos de accidentes masivos (*mass torts*), en aquellos en los cuales los daños se manifiestan al cabo de muchos años, acaso de décadas, de exposición de las víctimas a sustancias tóxicas (*toxic torts*) o de la realización de actividades que causan enfermedades óseas, cardiovasculares o de otro tipo (*working place accidents*): en estos casos y en otros semejantes, el derecho regulatorio, el establecimiento de fondos de compensación específicos o, aún mejor, la asunción de los costes de los accidentes y enfermedades por los sistemas generales de la seguridad social pueden constituir una alternativa al derecho de daños, cuyo lugar debe ceñirse al tratamiento de los casos más graves o de los residuales. Al respecto, puede verse Alberto AZAGRA MALO, *La tragedia del amianto y el derecho español*, 1ª ed., Atelier, Barcelona, 2007 y *Daños del amianto: litigación, aseguramiento de riesgos y fondos de compensación*, 1ª ed., Fundación Mapfre – Instituto de Ciencias del Seguro, Madrid, 2011.

1.6.2. Análisis económico del derecho/*Economic Analysis of Law*

El análisis económico del derecho reduce las categorías de daño a dos:

- **Daños patrimoniales o pecuniarios**, es decir, aquellos que afectan a bienes o servicios que pueden ser objeto de tráfico y, por tanto, de valoración en un mercado legal. Por ejemplo: daños causados a un automóvil, a un edificio, o daños que imposibilitan a un profesional desarrollar su actividad profesional durante unos días, semanas, meses o años.

- **Daños no patrimoniales o morales**. Son los que se causan a bienes únicos, insustituibles, o, por decirlo de otro modo, a personas o a bienes que no son objeto de tráfico, ni por tanto de apreciación, en ningún mercado, sea ya porque no existe, sea ya porque la ley no admite su existencia o funcionamiento: hay, efectivamente y como escribe Michael Sandel, bienes que no se pueden comprar (Michael J. SANDEL, ***What Money Can't Buy****: The Moral Limits of Market*, 1st ed., Farrar, Straus and Giroux, 2012): no está bien comprar un esclavo, no se puede vender un amigo a los amigos, no es fácil comprar amor, ni suele parecer razonable comerciar hijos, la lista es potencialmente muy larga pero solo su contenido básico no es polémico, pues hay mucha controversia en sus márgenes, pero esta es una cuestión que solo se puede analizar cumplidamente con conocimiento de causa, más adelante. En todo caso, hace más de un siglo que los ordenamientos de los países de nuestra cultura reconocen que los daños causados a objetos únicos, irremplazables, imposibles de comprar o vender, o muchos de los daños personales –y paradigmáticamente, la muerte en muchos casos (no en todos)—son indemnizables de alguna manera. El problema suele ser cómo, pues ¿cómo valorar la pérdida de un hijo?, ¿cómo indemnizar un daño cuya ocurrencia futura nadie o casi nadie aseguraría?, ¿cómo valorar la destrucción de la única fotografía del padre?, ¿el atropello mortal de nuestra vieja perra de trece años de edad, atrítica, sorda y casi ciega?, ¿cómo el insulto vulgar de quien, disparándose un tiro en el zapato, le chilla a otro ---"¡Eres un auténtico hijo de puta"!—o el del cínico bien leído y exquisitamente educado, que, sonriendo, susurra ---¡"Huérfano, que eres como Jon Snow"! ?

1.7. Responsabilidad civil y penal / *Tort and Crime*

En derecho de accidentes y en general, interesa la distinción entre derecho público y derecho privado: el derecho público establece infinidad de regulaciones que establecen, *ex ante*, cuáles son las condiciones de seguridad (precauciones) bajo las cuales puede desarrollarse tal o cual actividad y, *ex post*, las consecuencias de no haber observado las precauciones establecidas, normalmente, una multa pecuniaria, pero también, la suspensión de la actividad, su cese, o, incluso, la imposición de penas en sentido estricto (aplicación del derecho penal). En España, a diferencia de lo que ocurre en los países de nuestra área cultural, los delitos y faltas tipificados en el Código Penal comportan una pena, una sanción específicamente penal, pero además, en el mismo proceso en el cual se ventilan las eventuales responsabilidad penales de los imputados, se resuelve sobre sus responsabilidades estrictamente civiles o aquellas de las personas de quienes dependen.

El derecho penal, el derecho de la responsabilidad penal es primariamente derecho público que tutela intereses públicos: los consistentes en evitar la comisión de delitos y en restablecer la justicia quebrantada por el delincuente. El derecho civil de daños, el derecho de la responsabilidad civil no es incongruente con el anterior, pues también pretende abordar la reducción razonable o la supresión de riesgos que afectan a miembros de la colectividad o a toda ella. Pero ello se consigue, en el caso del derecho civil, con pretensiones puramente civiles ejercitadas normalmente en un proceso civil y queda siempre a la decisión del demandante la relativa al ejercicio de la pretensión de daños. El derecho de daños es privado por dos razones: el demandante elige entre accionar o no hacerlo y la indemnización que, en su caso, obtenga, quedará en su patrimonio, no es ninguna multa que engrose las arcas de la Hacienda Pública.

Sin embargo, ya hemos señalado que un mismo acto puede ser, al mismo tiempo, un delito (o falta) y un supuesto de responsabilidad civil: de derecho, todos los delitos y faltas pueden general una acción de responsabilidad civil por los daños eventualmente causados, acción que, normalmente, se ejercerá en el proceso penal, pero que los afectados pueden reservarse para ejercitarla en un proceso civil independiente (art. 112 LECr), algo que raramente sucede.

1.8. Responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad (también civil, pero) contractual / *Tort and Contract*

En derecho privado interesa la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual o civil (derecho de daños en sentido estricto). En una primera aproximación, la conducta cuya realización implica el incumplimiento de un contrato conlleva la responsabilidad de la parte incumplidora frente a su contraparte, pero no es considerada un supuesto de responsabilidad civil. Por ejemplo, el incumplimiento de un contrato de transporte de personas no genera responsabilidad civil aunque, claramente, pueda dar lugar a responsabilidad contractual en los términos previstos por el contrato mismo o la ley. Sin embargo, si, con ocasión del transporte, quien lo realiza, hiere o veja al viajero, este dispondrá de una pretensión específica de responsabilidad civil con independencia de las que puedan derivarse del contrato mismo.

En virtud de lo genéricamente establecido por el art. 1255 CC o, menos formalistamente, en virtud del ingenio precisamente humano, los humanos mismos y las organizaciones creadas por ellos pueden entablar relaciones contractuales muy diversas y con un contenido infinitamente diverso: el incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de una de las partes en un contrato válido da derecho a la otra a llevar a la primera ante un Juez para que este establezca las consecuencias de la infracción según el mismo contrato. Así, los deberes y obligaciones contractuales son creados por el ingenio y promesas de las partes del contrato. En cambio, los deberes derivados del derecho de daños dimanan directamente de la legislación y de los reglamentos aplicables o del derecho judicial, al margen de todo pacto o acuerdo entre las partes.

En el *Common Law,* la responsabilidad contractual es fundamentalmente objetiva, mientras que la responsabilidad civil es mayormente por negligencia. Sin embargo, en el *Civil Law* y, concretamente, en derecho español, la responsabilidad contractual parte de un principio general de negligencia, aunque la cuestión es muy discutida.

En la práctica, la dinámica del derecho de contratos es estrictamente privada: los contratos surgen y se desarrollan de abajo arriba –*bottom-up*—a partir de las soluciones ingeniadas por los abogados de las partes, para cada sector del tráfico económico, ante el desarrollo de la tecnología y la comercialización de nuevos productos y servicios cuyo acceso al mercado y distribución exigen nuevas soluciones contractuales. En cambio, la dinámica del derecho de daños, de responsabilidad civil, es regulatoria –*top-down*- o judicial –*bottom-up*, pero pública. Ello genera diferencias estructurales importantes: el derecho de contratos mira a crear o facilitar rutas comerciales, tráfico económico y solo secundariamente litigación. En cambio, el derecho de daños está centrado en la litigación, pues su énfasis está puesto en la reclamación de una indemnización de daños y perjuicios en un proceso judicial. La diferencia es tan marcada que, en algunos países, los abogados de contratos y los abogados de litigación se diferencian claramente los unos de los otros.

La **STS, 1ª, 349/2012, de 11 de junio** resuelve la cuestión relativa a si el propietario de una finca que la contamina en ele ejercicio de una actividad industrial lícita y que después vende la finca misma responde extracontractualmente frente al tercer adquirente por los daños económicos sufridos.

En palabras del Tribunal Supremo:

"Se trata de decidir si una sociedad mercantil constituida por entes públicos para la regeneración y consiguiente explotación de un puerto deportivo-pesquero y su zona residencial contigua puede repercutir retrospectivamente los costes de la descontaminación a la sociedad mercantil que en tiempos contaminó la zona, y ello pese a haber tenido que cesar esta en su actividad industrial y haber vendido en su día los terrenos a bajo precio debido precisamente a su contaminación, conocida por todas las entidades que sucesivamente fueron adquiriendo derechos sobre dichos terrenos. Y esta decisión se somete por la actora-recurrente a la jurisdicción civil con base en el Código Civil pero invocando el principio "quien contamina paga" , presente en diversas normas administrativas de protección medioambiental que se consideran aplicables al caso".

Hechos:

Ercros, S.A. "explotaba desde el primer tercio del siglo XIX una fábrica sita en un terreno de su propiedad ubicado en la fachada marítima de Badalona, y destinada a la fabricación de … productos químicos y abonos en general… siendo su actividad la de gran industria".

El 7.5.1987, la Corporación Metropolitana de Barcelona (luego Consell Comarcal Barcelonés) aprobó el Plan Especial de la Fachada Marítima de Barcelona, que contemplaba la ubicación del futuro puerto de Badalona al norte de los mencionados terrenos, y los calificaba como terrenos para pequeña y mediana industria, con la excepción de una zona destinada a uso residencial.

El 14.5.1987, Ercros, S.A. vendió mediante escritura pública a la Corporación una porción de terreno de unos 71.000 m² ubicada en primera línea de mar por 3.906.579 euros (650 millones de ptas.). En ese momento, el precio de mercado del terreno vendido era muy superior, de 5.318.957 euros (885 millones de ptas.). Los terrenos estaban altamente contaminados porque presentaban un elevado contenido de plomo y arsénico.

El 31.7.1987, Ercros cesó su actividad industrial y consta acreditado que, con posterioridad, el lugar fue utilizado como zona de extracción de arenas y vertido incontrolado de residuos de diferentes procedencias

En 1989, Ercros vendió el resto de los terrenos a Prima Inmobiliaria, S.A., que, a su vez, se los vendió mediante escritura pública el 9.5.1990 a Inmobiliaria Industrial Urbana, S.A. y esta, a su vez, se los vendió al ICO en 1994 en pago de deudas.

En 1991, el Ayuntamiento de Badalona decidió ubicar el puerto en los antiguos terrenos de la demanda, pese a ser conocida la contaminación de la zona por los estudios que había iniciado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en 1990, y dividió la zona en dos polígonos: uno destinado a suelo residencial y el otro a sistema portuario. El Gobierno de la Generalitat aprobó el proyecto de construcción del puerto deportivo de Badalona y otorgó a Marina Badalona, S.A., sociedad participada al 50% por el Consell Comarcal Barcelonés y el Ayuntamiento de Badalona, la concesión para la construcción y explotación del puerto, con asunción, entre otras obligaciones, de descontaminar los terrenos.

En 2001, 2002 y 2003 el Consell Comarcal Barcelonés aportó la porción de terreno que había comprador a Ercros a Marina Badalona, S.A. como aportación no dineraria con ocasión de tres sucesivas ampliaciones de capital realizadas en tales años. Del valor de la finca se descontaron en aquel momento 3.432.981 de euros (571 millones de ptas.) en concepto de gastos de descontaminación.

El 19.12.2002 y por escritura pública, ICO vendió a Marina Badalona, S.A. los terrenos que originariamente habían pertenecido a Ercros haciendo constar que tales terrenos iban a verse afectados por las obras de construcción del puerto de Badalona y que como existía un remanente de contaminación del suelo el coste de la contaminación (valorado en 8.005.481 euros) debía descontarse del precio de la venta de los terrenos, que quedaba en 11.419.230 euros.

Procedimiento:

Marina Badalona, S.A. demandó a Ercros, S.A. y le reclamó el pago de 25.444.530,10 euros por daños y perjuicios asociados a la contaminación de las fincas con base en el art. 1902 CC, pero también en haber cumplido con la obligación de descontaminación que incumbía a Ercros, por lo que invocaban la subrogación, el reembolso la repetición y el enriquecimiento injusto, así como la STSJ de Cataluña núm. 308/2004 de 28.4.2004, que habría impuesto a Ercros la obligación de descontaminación.

El 3.6.1997 la Junta de Residuos de la Generalitat de Cataluña había dirigido a Ercros, S.A. un requerimiento para que en el término de dos meses procediese a la retirada de escombros y residuos y a la realización de un estudio sobre el alcance de la contaminación. Requerimiento que fue reiterado el 26.6.1997 y el 28.11.1997. Ercros presentó un recurso administrativo contra el último requerimiento de la Junta, que fue inadmitido el 11.11.1998. Ercros, a su vez, interpuso un recurso ordinario contra la inadmisión, que el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya desestimó mediante resolución de 31.1.2000. Ercros interpuso recurso contencioso-administrativo esta última resolución y el TSJ de Cataluña en Sentencia de 28.4.2004 lo admitió en el sentido de revocar las decisiones administrativas en cuanto a sus pronunciamientos de inadmisibilidad del recurso y, entrando en el fondo del asunto, desestimó el recurso contra la resolución de la Junta de 28.11.1997:

"[E]l apartado a) del ... artículo 15 [de la Ley 6/1993, de 15 de julio, de residuos de Cataluña] considera como responsable directo de la regeneración de los espacios degradados por descargas incontroladas a la persona que ha efectuado la descarga y solidariamente al productor o el poseedor del residuo, siendo responsable únicamente subsidiario de la misma..., según su apartado b), el propietario de la finca ...o en su caso el titular del dominio público afectado, y constituyendo obligación del productor y del poseedor de los residuos, según el art. 17.1.a), la de garantizar su gestión de acuerdo con sus prescripciones desde luego inmediatamente aplicables a un requerimiento de descontaminación producido bajo su vigencia, y ante una contaminación que se mantuvo en el tiempo tras ella, cualesquiera que fuesen los acuerdos, privados o incluso de carácter o alcance urbanístico, que pudieran haberse alcanzado al momento de la venta de los terrenos" (FD. 5º).

La SJPI nº 27 Barcelona (8.1.2008) estimó en parte la demanda y condenó a Ercros al pago de 8.895.785,28 euros. En apelación, la AP (Sección 16ª) de Barcelona (31.3.2009) estimó el recurso de apelación interpuesto por Ercros, S.A., desestimó el de la demandante, y revocó la SJPI, desestimando la demanda:

"El coste de la descontaminación de un suelo contaminado debe ponerse en relación con el uso urbanístico de ese suelo... [en este sentido, art. 15 Ley 6/1993, en su redacción dada por la Ley 9/1998, y actual art. 19 b Decret Legislatiu *1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus*: "Que les persones causants de la contaminació d'un emplaçament resten obligades a sanejar-lo en funció de l'ús urbanístic que tenia quan el van transmetre. No es poden requerir mesures de sanejament complementàries vinculades als nous usos urbanístics del sòl, llevat que hagin estat promoguts per elles mateixes" (…)

"[L]a reclamación fundada en el art. 1902 producía una sensación de perplejidad porque los daños se habrían causado a una finca propia de la demandada cuando ejercía una actividad industrial que cesó en 1987;... descartada cualquier obligación contractual de Ercros para con Marina, ya que ésta no compró directamente los terrenos a aquella ni funda su demanda en acciones derivadas del contrato de compraventa, tampoco cabía la responsabilidad extracontractual por faltar el elemento de alteridad, como consideró la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 rectificando el criterio de la de 29 de octubre del mismo año...; en último extremo, la acción para exigir responsabilidad civil extracontractual habría prescrito conforme al art. 1968 CC, pues el caso no sería de daños continuados sino permanentes y, además, conocidos desde mucho años antes de la interposición de la demanda, de modo que nada habría impedido... reclamar en su momento por los daños, al margen de una responsabilidad por saneamiento que parece haber sido asumida y resuelta convencionalmente en su momento" (...)

"La demandante no hizo propiamente una regeneración del solar por sustitución de una obligación concreta y exigible a la demandada impuesta por la Administración en interés general, sino que lo que hizo fue urbanizar la zona en propio interés y, ciertamente, ello implicó la descontaminación de la finca" (FD. 2º STS).

Marina Badalona, S.A. interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. El segundo, por infracción de los arts. 1210 y 1158 CC, arts. 33, 43 y 45 CE y art. 1902 CC, así como por infracción del art. 1968 CC. El TS desestimó ambos recursos y confirmó la SAP:

"[E]ntre los dos referidos criterios opuestos de decisión [el de la STS, 1ª, de 29.10.2008 (RJ 5801), en la que el Tribunal Supremo condenó a Ercros con base en la responsabilidad extracontractual y el de la STS, 1ª, núm. 1135/2008 de 22.12.2008, en la que el Tribunal, en cambio, le absolvió porque los daños fueron causados a una finca propia] esta Sala considera que debe reiterar [el segundo criterio, según el cual] (FD. 4º):

"Cuando se trata de daños originados en la cosa vendida … el daño sufrido por el comprador resulta, en principio, del deficiente cumplimiento o del incumplimiento del contrato de compraventa; la relación de responsabilidad que resulta del cumplimiento o deficiente incumplimiento tiene el mismo alcance subjetivo que el que media, dentro de la órbita contractual, entre el que causa el daño (vendedor) y el que lo recibe (comprador); el ordenamiento jurídico prevé consecuencias específicas para los casos de defectos en la cosa vendida; y, finalmente, los bienes afectados son de carácter patrimonial, en tanto no se demuestre la afectación de bienes o derechos de mayor trascendencia. En suma, los daños originados en la cosa vendida que suponen un menoscabo de su valor o una imposibilidad de dedicarla al uso al que está destinada deben ser reclamados mediante el ejercicio de las acciones contractuales que correspondan, entre las cuales figuran las acciones para pedir el saneamiento de la cosa por vicios o defectos ocultos (acción redhibitoria y *quanti minoris* [de disminución del precio 'en cuanto menos']) o la acción resolutoria dimanante del incumplimiento del contrato cuando la cosa entregada es sustancialmente distinta de aquélla que se pactó como objeto de la compraventa o inhábil para el uso a que se destina (una cosa por otra, o *aliud pro alio*).

Esta reclamación debe ir dirigida contra el vendedor mediante, si procede, la subrogación que a tenor del artículo 1511 CC se opera en favor del comprador respecto de las acciones que corresponden al primero contra los transmisores anteriores…

El hecho de que el comprador no sea el primer adquirente no lo autoriza por sí mismo para el ejercicio de acciones de responsabilidad extracontractual contra los anteriores propietarios por los daños que haya sufrido la cosa vendida" (FD. 4º, véase un análisis de las SSTS de 2008 en Sonia RAMOS GONZÁLEZ y Rosa MILÀ RAFEL, "Responsabilidad civil y daños a los propios bienes", InDret 3/2009).

En último extremo, aunque se admitiera una obligación *ex lege* de Ercros, resultaría que esta ya se habría cumplido frente a la demandante, como razona la sentencia impugnada, mediante los sucesivos descuentos del coste de la descontaminación en los negocios jurídicos privados de transmisión de los terrenos" (FD. 5º).

1.9. ¿Es el derecho de daños una especialidad bien definida?

Sí, pero quizás sólo por oposición al derecho de la responsabilidad contractual o al derecho sancionador y, desde luego, está mucho menos definido en España que en otros países, señaladamente, que en los Estados Unidos de América.

El derecho de daños tiene una especificidad clara y distinta si se analiza desde el punto de vista del remedio típico que le es paradigmáticamente propio: las acciones de reparación e indemnización de daños. **Los remedios dan unidad al derecho de daños**.

Pero casi nada más lo hace: hoy en día, en un país occidental tecnológicamente avanzado es crecientemente difícil de concebir que una abogada esté especializada, al mismo tiempo, en litigación derivada de difamación, de protección de datos, de daños masivos, de accidentes de circulación, de daños biofarmacéuticos, de prevención de riesgos laborales, de exposición a sustancias tóxicas, etc. La razón es que el derecho de daños descansa sobre regulaciones crecientemente intrincadas y su conocimiento y dominio es, en la práctica, condición necesaria de la viabilidad de un escrito de demanda de reclamación de cantidad por daños y perjuicios. Nadie domina a la vez el acoso sexual, la difamación, la litigación por inhalación de sustancias tóxicas o los accidentes de aviación. Ya no.

Mas queda, anclado bien en el análisis de los remedios, algún otro punto de apoyo a la idea de la unidad positiva del derecho de daños –es decir, a la idea de que este se define por algo más que por su contraposición al derecho de contratos, al derecho penal y al derecho regulatorio---

Así, y en primer lugar, la cuestión de la culpa, de la negligencia del demandado ocupa un lugar central en casi todos los casos de derecho de daños regidos por el estándar de la culpa misma, como es el supuesto general del derecho del art. 1902 del Código Civil español de 1889.

Más aún, en torno a las cuestiones la causalidad en sentido amplio, que abarcan la causalidad empírica o de hecho (*Cause in Fact*) y causalidad, de derecho, normativa o imputación objetiva (*Proximate Causation, Scope of Liability*), comunes a la responsabilidad por negligencia y a la objetiva.

Luego, la naturaleza esencialmente procesal del ejercicio de las acciones y pretensiones de derecho de daños centran a la responsabilidad civil en torno a su litigación y transacción: a diferencia del derecho de contratos, que es extrajudicial y *ex ante*, el derecho de daños es judicial y *ex post*. En los países con juicio de jurado para la responsabilidad civil, la unidad procesal y profesional del derecho de daños aún es más marcada, pero no es el caso de España.

Finalmente, esencial al derecho de daños, es su dinamismo: el cambio forma parte de su naturaleza. El contrato pretende atar el futuro, el derecho de daños reanudar el pasado.

1.10. ABC de un pleito de daños

Explicación al abogado de los hechos, averiguación y análisis para ver si el cliente tiene pretensiones razonables (si hay una o más *legal issues* razonablemente planteables ante un tribunal); luego análisis de posibilidades de mediación, arbitraje o transacción (*Alternative Dispute Resolution*); redacción de la demanda o de la contestación, audiencia previa, juicio, pruebas, conclusiones, sentencia, apelación...

— Consulta de documentos relativos a un pleito de responsabilidad civil por daños causados por incendio.

a) Escrito de demanda
b) Escrito de contestación a la demanda
c) Sentencia del Juzgado de Primera Instancia
d) Sentencia de la Audiencia Provincial

Sesión 3ª

2. Negligencia

2.1. Panorama de la negligencia: la negligencia como infracción de deberes de precaución

STS, 1ª, 679/2010, de 10 de diciembre. Responsabilidad civil médica por error de diagnóstico.

El 12.12.1996, Eva se sintió súbitamente enferma, perdió el habla, sintió cosquilleos con adormecimiento y pérdida de la fuerza en el brazo derecho. Acudió al Hospital General de Caranza, donde fue atendida de urgencias por el médico de guardia Pío, quien le diagnosticó una bajada de azúcar, le inyectó glucosa y le dio de alta. Tres días después, Eva volvió a presentar la misma sintomatología y acudió nuevamente al mismo servicio de urgencias, donde fue atendida por el doctor Luis Miguel, quien ordenó su ingreso. En la madrugada del día siguiente, ante la situación de la paciente, el doctor Carlos decidió trasladarla a un nuevo centro hospitalario donde se le pudo realizar un TAC. En el nuevo centro se le diagnosticó un infarto isquémico cerebral. Como consecuencia de ello, Eva quedó con una afasia de tipo motor, problemas en el habla, alexia, agrafía, parálisis espástica de extremidad superior derecha con contractura en flexión de dedos y parálisis espática en la extremidad inferior derecha.

Eva demandó a Pío, a Luis Miguel, a Carlos, al "Hospital General de Caranza Ferrol" y a las compañías de seguros "Compañía de Seguros Aegon" y "Compañía de Seguros Ama Previsión Sanitaria S.L." y solicitó una indemnización de 780.000€ por los daños y perjuicios sufridos.

EL JPI núm. 6 de Ferrol (16.2.2004) desestimó la demanda. La AP de La Coruña (Sección 5ª, 4.12.2006) desestimó el recurso de apelación.

El TS estimó en parte el recurso de casación interpuesto por la actora y condenó a Pío y a las compañías de seguros (a estas hasta el límite de los seguros concertados) al pago de 235.112,98€:

"[A] la relación causal material o fáctica ha de sumarse el reproche causabilístico, sin lo cual no hay responsabilidad sanitaria, como sucede en este caso, si bien solo respecto de la actuación negligente o culposa del Dr. Pío por consecuencia de un error de diagnóstico que desembocó en el resultado dañoso generador de la responsabilidad, puesto que produjo un tratamiento equivocado, ineficaz y perjudicial para la paciente, que se identifica a partir de la valoración de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento en que los hechos tuvieron lugar y no después, al haberla dado de alta sin haber confirmado o descartado dicha lesión, cuando la sintomatología así lo exigía, sin que ello suponga, por tanto, una regresión a partir del desgraciado curso posterior seguido por la paciente (…)" (FD 2º).

— Encarna ROCA TRIAS/Mónica NAVARO MICHEL, *Derecho de daños*, 6ª edición, 2011, pp. 27-28:

"El retorno a la culpa como criterio de imputación": "el Tribunal Supremo ha vuelto a los criterios de imputación subjetiva" [a la culpa como criterio general por oposición a la responsabilidad objetiva].

— Pablo SALVADOR/Carlos GÓMEZ, "El Derecho de Daños y la Minimización de los Costes de los Accidentes", *InDret* 1/2005 (www.indret.com), pp. 3-6:

"El derecho de daños puede contribuir a reducir los costes de los accidentes por el procedimiento de establecer quién ha de cargar con sus consecuencias. Así, si se asume que el objetivo es minimizar los costes de los accidentes, ello resultará algo sencillo de conseguir en algunos casos, pero de dificultad variable y creciente en otros, como se muestra a continuación:

1. En un primer caso resuelto por la **STS, 1ª, 813/1997, de 26 de septiembre**, un cirujano del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, dependiente del Instituto Nacional de Salud (INSALUD), intervino a principios de 1984 a la actora, una mujer mayor, para extirparle un quiste ovárico. Durante la intervención, un minúsculo (4x3 mm.), de uno de los retractores empleados para separar las paredes abdominales y abrir un campo quirúrgico suficiente para operar, que estaba muy flojo, se soltó y cayó en las entrañas de la paciente. Nadie, ni el cirujano, ni sus ayudantes se percataron de ello. Años después, la presencia del tornillo en el abdomen de la víctima fue detectada casualmente en unas radiografías practicadas con motivo de un accidente doméstico. En junio de 1987, otro cirujano del mismo hospital intervino a la actora para retirarle el tornillo que, tras más de tres años en el interior de la víctima, se había adherido a las paredes del útero y, por ello, hubo que practicarle una histerectomía (extirpación total o parcial del útero). La víctima demandó a ambos cirujanos y al INSALUD y solicitó una indemnización de 60.000 euros. El JPI estimó en parte la demanda: condenó al INSALUD y absolvió a los facultativos. La sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Zaragoza y el Tribunal Supremo. La responsabilidad se imputa a quien hubiera podido evitarlo más fácilmente: "se exime de responsabilidad a los facultativos intervinientes, por haberse ajustado a la 'lex artis ad hoc' [...y] se le imputa la responsabilidad al ente recurrente [INSALUD] por lo que respecta al material preciso para la intervención, que el mismo no había sido conservado con la exquisita atención o diligencia; cometido este, que incumbe al ente recurrente" (FD 2º).

Cinco años después, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en **STS, 1ª, 1152/2002, de 29 de noviembre**, resolvió un caso muy similar. En esta ocasión, el cirujano demandado intervenía en noviembre de 1974a un hombre de 34 años de edad para extirparle un tumor en la espina dorsal. Durante la operación, el facultativo dejó olvidada una gasa alrededor de la columna lumbar del paciente y, por ello, hubo de intervenirlo de nuevo tres meses más tarde. Con posterioridad a esta segunda operación, el paciente presentó unas secuelas irreversibles que dieron lugar a su incapacidad permanente absoluta. El actor demandó al cirujano y solicitó 240.404,84 euros. El JPI y la AP desestimaron la demanda al entender que no había prueba suficiente del nexo causal entre la gasa olvidada y la incapacidad. El Tribunal Supremo casó la sentencia absolutoria de la Audiencia y dictó nueva sentencia en virtud de la cual aplicó la doctrina del daño desproporcionado en la responsabilidad civil médica y condenó al cirujano a abonar una indemnización por daño moral de 120.000 euros. El Tribunal omite las razones para cuantificar la indemnización en la mitad de lo solicitado.

Ambos son casos claros de negligencia unilateral, es decir, supuestos en los cuales la víctima nada podía haber hecho para evitar el daño que finalmente sufrió, cuando, además, queda bien a las claras que los demandados podían haber adoptado más y mejores precauciones.

El caso siguiente plantea más dificultades tanto a la hora de identificar a los responsables de los daños sufridos por la víctima como a la de concretar las medidas que podrían haberse adoptado para evitarlos:

2. Una mañana del mes de marzo de 1992, la víctima esperaba la llegada del Metro en la estación de la calle Rocafort de Barcelona. El convoy llegó, abrió las puertas y la abigarrada muchedumbre que esperaba en el andén se abalanzó hacia el interior de los vagones. Empujada por el resto de viajeros, la víctima cayó al suelo y sufrió lesiones de gravedad por las que reclamó un total de 37.743,55 euros a la entidad "Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA" gestora del servicio público de transporte por metro en la ciudad de Barcelona cuando de produjo el accidente. La Audiencia Provincial estimó el recurso de la víctima contra la sentencia desestimatoria de la demanda de la primera instancia y concedió una indemnización de 28.518,02 euros con cargo a la entidad demandada. La **STS, 1ª, 1121/2001, de 3 de diciembre**, que puso fin al proceso, desoyó los argumentos de "Ferrocarril Metropolità" y convalidó la condena decidida por la Audiencia de Barcelona.

El tercer caso que presentamos a continuación manifiesta aún más palmariamente las dificultades de atribuir responsabilidad al titular de una organización por los daños causados por un tercero ajeno al ámbito de influencia de la organización misma:

3. En la madrugada del 6 de mayo de 1990, la Sra. Ángela M.R. entró en una de las oficinas de la entidad bancaria demandada para retirar dinero de un cajero automático. En nuestro país, algunas oficinas de bancos y cajas disponen de cajeros a pie de calle, pero es más frecuente que tras la puerta de entrada de la oficina, haya un primer espacio en el que están instalados uno o varios cajeros automáticos, que pueden ser usados, por lo general, las 24 horas del día. La puerta de acceso a este local puede cerrarse con un pestillo. Durante las horas de oficina, los clientes pueden superar este espacio y entrar donde se encuentran los empleados que ofrecen los servicios bancarios de que se trate. En el asunto, el pestillo de la puerta estaba roto y un atracador, que estaba al acecho, entró en el local cuando la víctima ya había tecleado el número secreto de su tarjeta de crédito. Forcejearon, el atracador sacó una navaja con la que hirió a la actora en su mano izquierda y le robó la cantidad retirada. La víctima reclamó 90.152 euros a la entidad bancaria titular del cajero automático. En primera instancia, su demanda fue estimada en parte, pero la entidad demandada recurrió en apelación y la Audiencia Provincial desestimó íntegramente la demanda. El Tribunal Supremo, en **STS, 1ª, 255/1997, de 1 de abril**, desestimó el recurso de la víctima: "[…] no puede afirmarse que las lesiones sufridas por la recurrente al ser asaltada por un desconocido, sean una consecuencia […] del estado en que e encontraba el cerrojo instalado en la puerta de acceso al cajero automático y que impedía cerrar la puerta desde el interior, sino que tales lesiones son imputables exclusivamente, en una relación de causa a efecto, a la violencia ejercida sobre la actora por el tercero desconocido que la atacó" (FD 2º).

En ocasiones, quien causa el accidente es su víctima. En otras, el responsable nada tuvo que ver con el accidente que motiva finalmente su responsabilidad. En unas terceras, la víctima carga con las consecuencias del daño que sufre. La imputación de daños no depende siempre del relato causal. Así lo confirman los dos casos siguientes.

4. La **STS, 1ª, 2034/1997, de 31 de diciembre** condenó a la Red Nacional de Ferrocarriles (RENFE) por la muerte de dos menores de edad quienes, durante las fiestas mayores del pueblo de Manzanares (Madrid), jugaban con sus compañeros a ver quién aguantaba más sobre la vía del tren cuando se acercaba la locomotora. RENFE había denunciado varias veces los hechos al Ayuntamiento de Manzanares que había ordenado vigilar la zona durante unas horas al día. Fuera de ellas, grupos de muchachos volvían a la vía para hablar, reír, beber y jugarse la vida. El día 21 de julio de 1990, Miguel Ángel C. y José Gabriel P., ambos de quince años, estaban de pie sobre las vías, con 0,92 gramos de alcohol por litro de sangre el primero, cuando un Tren Expreso que circulaba a 130 km/h., les arrolló. Ambos murieron en el acto. Los padres de las víctimas reclamaron una indemnización de 150.253 euros al Ayuntamiento de Manzanares, a RENFE y al maquinista del tren. Las instancias condenaron únicamente a RENFE y al Ayuntamiento a pagar 36.061 euros a cada uno de los demandantes. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la compañía ferroviaria. La actividad de los jóvenes, en absoluto justificable, era conocida y debían haberse adoptado todas las medidas necesarias, incluso la detención del convoy a su paso por el pueblo, para evitar daños como los que sucedieron.

5. El demandante en el proceso que resolvió la **STS, 1ª, de 10 de octubre de 1998**era un trabajador de una empresa de productos congelados a quien una máquina termoselladora le amputó la mano derecha. Inmediatamente después del accidente, la enfermera de la empresa acudió al lugar de los hechos para atender al trabajador, cortó la hemorragia e instruyó a un compañero del trabajador para que envolviera la mano traumáticamente amputada en hielo natural. Mientras esperaban a la ambulancia, el compañero de la víctima metió la mano amputada en una caja de *porexpan* llena de dióxido de carbono sólido, comúnmente conocido como hielo seco, de las que utilizaban para el transporte de productos congelados, pues creía que procuraría una mejor conservación de la mano. Cuando la víctima fue ingresada en el centro sanitario los tejidos de la mano amputada estaban destruidos por congelación y no fue posible practicar el implante. El trabajador quedó manco de por vida y demanda a la empresa y a la enfermera de la misma por no haber comprobado cómo se trasladó la mano amputada al

hospital. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron la concesión de 120.202 € que el demandante reclama, pero el Tribunal Supremo condenó a la enfermera a pagar una indemnización de 9.015 euros. La enfermera no fue del todo diligente y debía responder por la pérdida de las expectativas de reimplantar el miembro amputado.

6. En el caso resuelto por la **STS, 1ª, 931/2001, de 17 de octubre**, un joven de 21 años practicaba descenso por aguas bravas en el río Gállego al cruzar un desfiladero de especial dificultad, el "Paso del Embudo" en el término municipal de Murillo (Zaragoza), cayó de la balsa neumática, se golpeó la cabeza con una roca y falleció en el acto. Poco después, el padre de la víctima demandó a la asociación organizadora de la actividad deportiva, a la compañía aseguradora y al monitor que había dirigido la actividad. Por el hecho se siguieron diligencias penales posteriormente archivadas. En el pleito civil, las sentencias de las instancias desestimaron la demanda. Igual suerte corrió el demandante en casación".

2.1.1. Negligencia y circunstancias personales del causante

2.1.1.1. Edad, minoría de edad, estado de salud

El criterio comúnmente adoptado por la mejor doctrina es que los niños de muy corta edad (los menores de 7 años aproximadamente) son inimputables –por ellos responden sus padres o guardadores ex art. 1903 CC-; es más, si el menor carece de capacidad natural –un niño de tres años de edad, por ejemplo-, no hay acción, no hay agencia social. Si el menor tiene capacidad natural –y patrimonio con el que responder-, entonces puede efectivamente ser condenado a indemnizar por los daños causados. Mas, en el derecho positivo, la cuestión solo ha sido regulada por el Código Penal, arts. 19, 118.1 y 120.1 CP y 3 y 61 y ss. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En particular, la LO 5/2000 considera penal y civilmente responsables a los menores de edad desde que cumplen los catorce años (arts. 1.1 y 61.3 LO 5/2000). Además, la doctrina mayoritaria admite la aplicabilidad del art. 1902 CC al menor civilmente imputable (Esther Gómez Calle (2006), "Los sujetos de la responsabilidad civil. La responsabilidad por hecho ajeno", en L. Fernando Reglero Campos (Coord.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, 3ª ed., Thomson-Aranzadi, Navarra, pp. 461-538, 480).

El derecho comparado de países próximos a nuestra cultura ofrece soluciones similares, pero discrepantes en el detalle de la regulación propuesta.

La jurisprudencia de la Sala 1ª del TS tiende a juzgar la conducta de los menores con edades comprendidas entre 7 y 15 años en términos de negligencia, pero el estándar de diligencia exigible es más leve que el de los adultos. Hay que tener en cuenta también que, si bien los tribunales tienden a excusar travesuras y avatares de los juegos propios de la infancia, no hacen lo mismo con la conducta claramente despreciativa de peligros que todo niño de su edad debería prever, y tampoco la conducta antijurídica: los terceros no tienen por qué anticipar y prevenir el daño conexo a un acto voluntario, arriesgado y a veces incluso ilícito cometido en vísperas de la pubertad (Josep FERRER I RIBA y Covadonga RUISÁNCHEZ CAPELASTEGUI, "Niños y adolescentes", *InDret* 1/2000, pp. 7 y ss.)

Responsabilidad civil de menores en derecho español

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Artículo 118.1.1:

1. La exención de la responsabilidad criminal declarada en los números 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 20, no comprende la de la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas siguientes:

1. En los casos de los números 1 y 3, son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los imputables.

Los Jueces o Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos.

Artículo 120. Responsables civiles subsidiarios

Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente:
1º Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia. (…)

STS, 2ª, 619/2005, de 11 de mayo

El 8.7.2002 en Medina de Pomar (Burgos), sobre las 17:30 horas, Rodrigo, nacido el 31.7.1983 (19 años), con una dotación intelectual inferior al promedio (entre la normalidad y el retraso mental leve) y educado en un contexto familiar desestructurado (abandono de la madre a los cuatro años de edad, y padre alcohólico), tras comprar en una tienda un cuchillo de unos 11 cms. de hoja, entró en la Óptica Medina Centro, sita en la misma calle que el primer establecimiento. Esperó a que la dependienta, Soledad, atendiese a otro cliente y, cuando se encontraban solos en la óptica, le solicitó que le graduase la vista, Rodrigo y Soledad entraron al gabinete habilitado al efecto y, después de realizada tal operación, Soledad se levantó para rellenar el correspondiente impreso, mientras el joven permanecía sentado. Rodrigo, entonces, clavó el cuchillo que portaba consigo en la zona abdominal de Soledad, causándole graves lesiones que tardaron 235 días en sanar y secuelas consistentes en cicatriz queloidea de 17 cms. de longitud y 1 cm. de anchura en la línea media abdominal, cicatriz de 2 cms. en hipocondrio izquierdo y síndrome de estrés postraumático. Cuando ocurrieron los hechos, Rodrigo se encontraba en Medina de Pomar, en salida autorizada por el centro en el que estaba ingresado (Residencia Los Robles de Villasante de Montija, Burgos). No consta que el titular de dicha residencia, Hogadema, S.A. (que tenía contratado el seguro de responsabilidad civil con Mapfre Industrial, S.A.), hubiera adoptado medida alguna para evitar los hechos.

La SAP Burgos, Secc. 1ª, 7.5.2004, condenó al acusado Rodrigo como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasiva durante el tiempo de la condena, y prohibición de aproximación a la víctima a una distancia inferior de 200 metros y de comunicarse en cualquier forma con ella durante cinco años. També condenó a Rodrigo a indemnizar a Soledad con 30.680 € por lesiones y con 20.000 euros por secuelas. De dichas cantidades había de responder directamente Mapfre Industrial, S.A., en solidaridad con Hogadema, S.A.

La STS, 2ª, 11.5.2005, estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto por Hogadema, S.A. de manera que se redujo la responsabilidad civil de esta entidad de solidaria a subsidiaria, ya que el TS consideró aplicable el art. 120.1 CP "al Organismo que tenía bajo su guarda y tutela a quien cometió un hecho delictivo por concurrir un cierto nivel de negligencia que guarda con el delito cometido una relación de causa/efecto". Y añadió que "en la sentencia de esta Sala 1527/2001, de 21 de julio, se declara que un requisito esencial de la responsabilidad civil subsidiaria es la existencia de una relación de causalidad –a la que se refiere claramente la expresión legal «siempre que haya mediado»– entre la culpa o negligencia de quienes tengan al exento de responsabilidad criminal –total o parcialmente– bajo su potestad o guarda y la comisión por aquél de un hecho punible (…); exclusión [de la responsabilidad del centro psiquiátrico] que no puede afirmarse en el presente caso (…) ya que no se produjo una cesión temporal de la guarda de hecho a favor de la familia o de tercera persona a quien le incumbiera la responsabilidad civil subsidiaria derivada de la actuación de Rodrigo, sino que se mantuvo la guarda de hecho por parte de Hogadema, S.A. durante las salidas autorizadas por su Dirección" (FD 2º).

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores

Artículo 1. Declaración general

1. Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.

2. También se aplicará lo dispuesto en esta Ley para los menores a las personas mayores de dieciocho años y menores de veintiuno, en los términos establecidos en el artículo 4 de la misma.

Artículo 5.Bases de la responsabilidad de los menores.

1. Los menores serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los hechos a los que se refiere el artículo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal.

2. No obstante lo anterior, a los menores en quienes concurran las circunstancias previstas en los números 1, 2 y 3 del artículo 20 del vigente Código Penal les serán aplicables, en caso necesario, las medidas terapéuticas a las que se refiere el artículo 7.1, letras d) y e), de la presente Ley.

3. Las edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender siempre referidas al momento de la comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitación del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores.

Título VIII
De la responsabilidad civil

Artículo 61. Reglas generales

1. La acción para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento regulado en esta Ley se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Se tramitará una pieza separada de responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados.

3. Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos.

4. En su caso, se aplicará también lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y sus disposiciones complementarias.

Artículo 62. Extensión de la responsabilidad civil

La responsabilidad civil a la que se refiere el artículo anterior se regulará, en cuanto a su extensión, por lo dispuesto en el Capítulo I del Título V del Libro I del Código Penal vigente.

STS, 1ª, 205/2002, de 8 de marzo

Patricia G.N., de 16 años, perdió la visión casi total del ojo derecho al sufrir un balonazo en la cara, lanzado por Mariano M.Q., de 17 años, que jugaba al fútbol con unos amigos, mientras estaba sentada en un banco del jardín municipal del Paseo de la Playa de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Georgina N.M., en nombre de su hija Patricia G.N., demandó a Mariano M.Q., a sus padres (Eusebio M.S. y Dulce Nombre Q.Z.) y al Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules y solicitó una indemnización de 90.151,81 euros.

El JPI nº 3 de Chiclana de la Frontera (29.12.1995) desestimó la demanda. La AP de Cádiz (Sección 5ª, 10.7.1996) estimó parcialmente el recurso de casación y condenó a Mariano M.Q. y a sus padres a satisfacer a la actora una indemnización de 60.101,21 euros.

El TS desestimó el recurso de casación y confirmó la SAP. No es necesario acudir a criterios de responsabilidad por riesgo para fundamentar la responsabilidad del menor. Basta analizar la imputación subjetiva del daño: la edad (17 años, 7 meses y 22 días) y los factores psicológicos del menor indican que podía haber previsto que jugando con un balón de cuero ligeramente deshinchado en un lugar inidóneo se podían causar daños a terceros ajenos al juego. La responsabilidad de los padres tiene su fundamento en la presunción de culpa contenida en el art. 1903 CC.

2.1.1.2. Edad, salud y responsabilidad civil en el derecho comparado

2.1.1.2.a Common Law

a) *Daniels v. Evans* (224 A.2d 63 (N.H. 1966))

[Plaintiff's decedent, a 19-year-old youth, was killed when his motorcycle collided with defendant's automobile. A trial by jury resulted in a verdict for plaintiff, and the only alleged error argued on appeal was the trial court's charge pertaining to the standard of care required of the decedent].

LAMPRON, J. As to the standard of care to be applied to the conduct of the decedent Robert E. Daniels, 19 years of age, the Trial Court charged the jury in part as follows:

"Now, he is considered a minor, being under the age of twenty-one, and a minor child must exercise the care of the average child of his or her age, experience and stage of mental development. In other words, he is not held to the same degree of care as an adult."

Concededly these instructions substantially reflect the rule by which the care of a minor has been judged heretofore in the courts of our state. However an examination of the cases will reveal that in most the minors therein were engaged in activities appropriate to their age, experience and wisdom. These included being a pedestrian, riding a bicycle, riding a horse [and] coasting.

We agree that minors are entitled to be judged by standards commensurate with their age, experience, and wisdom when engaged in activities appropriate to their age, experience, and wisdom. Hence when children are walking, running, playing with toys, throwing balls, operating bicycles, sliding or engaging in other childhood activities their conduct should be judged by the rule of what is reasonable conduct under the circumstances among which are the age, experience, and stage of mental development of the minor involved.

However, the question is raised by the defendant in this case whether the standard of care applied to minors in such cases should prevail when the minor is engaged in activities normally undertaken by adults. In other words, when a minor undertakes an adult activity which can result in grave danger to others and to the minor himself if the care used in the course of the

activity drops below that care which the reasonable and prudent adult would use, the defendant maintains that the minor's conduct in that instance, should meet the same standards as that of an adult.

Many recent cases have held that "when a minor assumes responsibility for the operation of so potentially dangerous an instrument as an automobile, he should . . . assume responsibility for its careful and safe operation in the light of adult standards." The rule has been recognized in Restatement (Second), Torts and in Prosser, Torts. In an annotation in [the] A.L.R. it is said that recent decisions "hold that when a minor engages in such activities as the operation of an automobile or similar power driven device, he forfeits his rights to have the reasonableness of his conduct measured by a standard commensurate with his age and is thenceforth held to the same standard as all other persons."

One of the reasons for such a rule has been stated thusly in Dellwo v. Pearson: "To give legal sanction to the operation of automobiles by teen-agers with less than ordinary care for the safety of others is impractical today, to say the least. We may take judicial notice of the hazards of automobile traffic, the frequency of accidents, the often catastrophic results of accidents, and the fact that immature individuals are no less prone to accidents than adults. . . . [I]t would be unfair to the public to permit a minor in the operation of a motor vehicle to observe any other standards of care and conduct than those expected of all others. A person observing children at play . . . may anticipate conduct that does not reach an adult standard of care or prudence. However, one cannot know whether the operator of an approaching automobile . . . is a minor or an adult, and usually cannot protect himself against youthful imprudence even if warned." [...]

RSA 262, which establishes rules of the road for the operation of motor vehicles on our highways, reads as follows: "Required obedience to traffic laws. It is unlawful and . . . a misdemeanor for any person to do any act forbidden or fail to perform any act required in this chapter." (Emphasis supplied). This is some indication of an intent on the part of our Legislature that all drivers must, and have the right to expect that others using the highways, regardless of their age and experience, will, obey the traffic laws and thus exercise the adult standard of ordinary care [...].

The rule charged by the Trial Court pertaining to the standard of care to be applied by the jury to the conduct of the minor plaintiff Robert E. Daniels in the operation of the motorcycle was proper in "the bygone days" when children were using relatively innocent contrivances. See A.L.R.. However in the circumstances of today's modern life, where vehicles moved by powerful motors are readily available and used by many minors, we question the propriety of a rule which would allow such vehicles to be operated to the hazard of the public, and to the driver himself, with less than the degree of care required of an adult.

We are of the opinion that to apply to minors a more lenient standard in the operation of motor vehicles, whether an automobile or a motorcycle, than that applied to adults is unrealistic, contrary to the expressed legislative policy, and inimical to public safety. Furthermore when a minor is operating a motor vehicle there is no reason for making a distinction based on whether he is charged with primary negligence, contributory negligence, or a causal violation of a statute and we so hold.

We hold therefore that a minor operating a motor vehicle, whether an automobile or a motorcycle, must be judged by the same standard of care as an adult and the defendant's objection to the Trial Court's charge applying a different standard to the conduct of plaintiff's intestate was valid.

Exception sustained.

b) *Purtle v. Shelton* (474 S.W.2d 123 (Ark. 1971))

GEORGE ROSE SMITH, Justice.

This is an action for personal injuries suffered by Jerry Purtle, a sixteen-year-old minor, in a hunting accident during the 1969 deer hunting season. The defendants are Kenneth Shelton and his son, Kenneth, Jr., who was seventeen at the time of the accident. The jury attributed half the negligence to Jerry Purtle and half to young Shelton; so there was no recovery. For reversal the appellant, Jerry's father and next friend, contends that the trial court erred in its instructions defining the standard of care to be observed by a minor while hunting deer with a high-powered rifle.

There were some conflicts in the testimony, but the salient facts are not really in dispute. Jerry and young Kenneth had spent the night at the home of L. D. McMullen, who owned a deer camp in Union county. Early the next morning, before daylight, McMullen took the two youths (and a third lad not involved in the case) to the area where they were to hunt. Kenneth's deer stand was next to the road, but Jerry had to walk a short distance through the woods to his stand. MaMullen had cautioned both boys to make their presence known when they were walking in the woods and not to shoot at anything without knowing it to be a deer.

Jerry failed to find his stand immediately and actually walked toward Kenneth's stand, without making his presence known. Kenneth thought he saw a deer and fired at it with his 30.06 rifle. The soft projectile apparently hit a tree, broke into shrapnel, and ricocheted toward Jerry, causing serious injuries to both his eyes.

The trial court submitted the case to the jury upon the theory that Kenneth was required to use that degree of care which a 17-year-old minor would use in the same circumstances. […]

We are unable to find any authority holding that a minor should be held to an adult standard of care merely because he engages in a dangerous activity. There is always the parallel requirement that the activity be one that is normally engaged in only by adults. So formulated, the rule is logical and sound, for when a youth is old enough to engage in adult activity there are strong policy reasons for holding him to an adult standard of care. In that situation there should be no magic in the attainment of the twenty-first birthday.

We have no doubt that deer hunting is a dangerous sport. We cannot say, however, either on the basis of the record before us or on the basis of common knowledge, that deer hunting is an activity normally engaged in by adults only. To the contrary, all the indications are the other way. A child may lawfully hunt without a hunting license at any age under sixteen. We know, from common knowledge, that youngsters only six or eight years old frequently use .22 caliber rifles and other lethal firearms to hunt rabbits, birds, and other small game. We cannot conscientiously declare, without proof and on the basis of mere judicial notice, that only adults normally go deer hunting.

In refusing to apply an adult standard of care to a minor engaged in hunting deer, we do not imply that a statute to that effect would be unwise. Indeed, we express no opinion upon that question. As judges, we cannot lay down a rule with the precision and inflexibility of a statute drafted by the legislature. If we should declare that a minor hunting deer with a high-powered rifle must in all instances be held to an adult standard of care, we must be prepared to explain why the same rule should not apply to a minor hunting deer with a shotgun, to a minor hunting rabbits with a high-powered rifle, to a twelve-year-old shooting crows with a .22, and so on down to the six-year-old shooting at tin cans with an air rifle. Not to mention other dangerous activities, such as the swinging of a baseball bat, the explosion of firecrackers, or the operation of an electric train. All we mean to say in this case is that we are unwilling to lay down a brand-new rule of law, without precedent and without any logical or practical means of even surmising where the stopping point of the new rule might ultimately be reached. […]

Affirmed.[…]

BYRD, Justice (dissenting).

“Because a bullet fired from the gun by a minor is just as deadly as a bullet fired by an adult, I'm at a loss to understand why one with ‘buck fever’ because of his *532 minority is entitled to exercise any less care than any one else deer hunting. One killed by a bullet so fired would be just as dead in one instance as the other and without any more warning.

For the reasons stated, I respectfully dissent”.

Restatement (Third) of Torts: § 10. Children

“(a) A child´s conduct is negligent if it does not conform to that of a reasonable person of the same age, intelligence, and experience, except as provided by section (b) or (c).

(b) A child less than five years of age is incapable of negligence.

(c) The special rule in Subsection (a) does not apply when the child is engaging in a dangerous activity that is characteristically undertaken by adults.”

§ 11 RTT. Disability

(a) The conduct of an actor with a physical disability is negligent only if the conduct does not conform to that of a reasonable careful person with the same disability.

(b) The conduct of an actor during a period of sudden incapacitation or loss of consciousness resulting form physical illness is negligent only if the sudden incapacitation or loss of consciousness was reasonably foreseeable for the actor.

(c) An actor´s mental or emotional disability is not considered in determining whether conduct is negligent, unless the actor is a child.

2.1.1.2.b Civil Law: Francia y Alemania

Francia : Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Article 3

“Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi”.

2.1.1.2.c Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbusch (BGB))

§ 828 Minderjährige

"(1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich.

(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, den er bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen zufügt, nicht verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt hat.

(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern Seine Verantwortlichkeit nicht nach Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat".

2.1.1.3. Víctimas especialmente sensibles. Eggshell Skull Doctrine or The Thin Skull Rule or You take your victim as you find him

¿Debe el demandado atender a las circunstancias personales de la víctima que la sitúan en una posición de extrema vulnerabilidad y que, a menudo, no son aparentes? La respuesta es afirmativa en todos aquellos casos o circunstancias en los cuales el demandado había de contar con la posible presencia de víctimas potenciales especialmente frágiles, por ejemplo, en las calles y plazas de la ciudad, en general, en los escenarios habituales de la vida cotidiana. La razón es sencilla de entender: si para medir la intensidad del deber de precaución no se tuviera en cuenta al 5% o al 10% o al 15% de población más frágil, los incentivos para comportarse adecuadamente serían subóptimos.

En cambio, en espacios o, en general, en ocasiones en las cuales el demandado puede contar con que aquellas personas con las cuales va a interactuar son homogéneamente sanas y fuertes, sus deberes de precaución no incluirán la consideración hacia aquellas que precisen de una protección especial salvo que su indefensión resulte aparente a ojos de un observador razonable. El ejemplo clásico es la práctica de un deporte de equipo y de contacto en un espacio cerrado, un estadio o un campo de deporte.

Los casos de la ley suelen seguir esta línea de razonamientos:

"One rule of the tort law … is that the defendant takes his victim as he finds him. In Smith v. Brain Leech & Co. Ltd (1962) 2 Q.B. 405, plaintiff's deceased was burned on his lip by splashing molten metal because defendant negligently failed to provide an adequate guard. Because of prior exposures of another kind in the past, deceased had (according to the court) developed a tendency toward cancer. In any event, the burned lip did develop a cancer from which he died. The court acknowledged that death by cancer was unforeseeable…" (EPSTEIN, Cases and Materials on Torts, 9th ed., p. 542).

2.1.1.4. Negligencia y riqueza del causante

¿Deben de tenerse en cuenta los medios de que dispone el demandado, su riqueza en términos económicos, culturales, biológicos? La respuesta es negativa en el caso de la riqueza económica, pero como veremos en seguida, hay muchas formas de riqueza que no son estricta y directamente mente económicos, aunque admitan valoración, al menos parcial, en tales términos:

— *Denver & Rio Grande R.R. v. Peterson* (69 P. 578 (Colo. 1902))

"CAMPBELL, C.J. The care required of a warehouseman is the same, whether he is rich or poor. For, if the fact that he is rich requires of him greater care than if he possessed only moderate

means or is poor, then, if he were extremely poor, the care required might be such as practically to amount to nothing; and no one would claim that such an uncertain and sliding rule should be the measure of his liability…"

2.1.1.5. Conocimientos especiales y habilidades particulares del demandado (o su ausencia)

El punto de partida en la responsabilidad profesional es que el demandado responde por el incumplimiento del cuerpo de reglas propias de su profesión, arte u oficio: la *lex artis*. ¿Pero responden más intensamente los mejores, en cada profesión, oficio o práctica o lo hacen de acuerdo con las reglas generales del arte, con la media de su profesión? ¿Está penalizado ser de los mejores? La respuesta suele ser que quien dispone de conocimientos especiales ha de actuar desde luego de acuerdo con las reglas propias del cuerpo de conocimientos correspondientes, es decir, más prudentemente que el lego. En cambio, dentro de la profesión u oficio, la respuesta es que la pericia extraordinaria del demandado es una de las circunstancias de que delimitan sus deberes de cuidado, pero no la única de ellas. En todo caso, quien carece de las habilidades propias de un especialista, no ya porque sea lego, sino porque, siendo profesional, dispone solo de los conocimientos generales de su oficio, ha de abstenerse de ejercer una especialidad para cuyo ejercicio no está preparado suficientemente.

§ 12 Restatement (Third) of Torts:

"If an actor has skills or knowledge that exceed those possessed by most others, these skills or knowledge are circumstances to be taken into account in determining whether the actor has behaved as a reasonably careful person."

- When the actor is one of a limited number of parties that engage in an activity that poses distinctive and significant dangers [electric-power company].

- When the actor that possesses an above-average knowledge has a pre-existing relationship with the other party. [STS, 1a, 836/2004, de 22 de julio]

- Substandard judgment is usually ignored. Learners and beginners.

- Intoxication. The foreseeability test: voluntary intoxication is ignored. Iced tea spiked with liquour.

En el ámbito de la profesión médica, existe la obligación del prestador del servicio de no actuar si carece de la competencia, especialización o diligencia necesarias para tratar la dolencia del paciente. En tal sentido, puede verse la **STS, 1ª, 679/2010, de 10 de diciembre**, ya citada *supra* (véase epígrafe 2.1): "Faltaron en el caso los conocimientos médicos necesarios para hacer posible el diagnóstico que hubiera prevenido o evitado la obstrucción completa de la arteria carótida a partir de una previa sintomatología neurológica que no fue detectada por el médico de guardia, como "sin duda" lo habría hecho el perito, lo que a la postre no viene sino a indicar que cualquier otro médico con una base mínima de conocimientos para estos supuestos o supliendo sus carencias mediante un consejo médico complementario, habría detectado de inmediato la razón de su ingreso y le hubiera proporcionado con la urgencia y diligencia necesaria todos los medios curativos de que disponía" (FD. 2º).

STS, 1ª, 798/2009, de 9 de octubre(en el mismo sentido, STS, 1ª, 815/2010, de 15 de diciembre). Comentada por Marian GILI SALDAÑA e Ignacio MARÍN GARCÍA (2009), "Sentencia de 9 de octubre de 2008 (RJ 2008, 6042)", *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil,* núm. 80, pp. 751-778.Fin de protección de la norma y ausencia de responsabilidad de auditores.

Desde 1993, "XM Patrimonios Agencia de Valores, S.A." creó la apariencia de que compraba valores por cuenta de clientes cuando, en realidad, desviaba los fondos que recibía a otras sociedades. "Price Waterhouse Auditores, S.A." auditó las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios de 1993 y 1994. Las auditorías, que fueron realizadas

efectivamente por Iván, no contenían salvedad alguna y expresaban la opinión de que las cuentas de la sociedad auditada reflejaban la imagen fiel de su patrimonio.

"Lepanto Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", Luis Enrique, "Penedés, S.A." y "Alto Penedés, S.A." demandan a "Price Waterhouse Auditores, S.A." e Iván, y solicitan una indemnización de 8.961.322,55 € para "Lepanto"; 1.526.244,80 € para Luís Enrique; 846.379,26 € para "Penedés, S.A.", y 65.599,71 € para "Alto Penedés, S.A.".

El JPI nº 24 de Barcelona (21.10.1998) desestimó la demanda. La AP de Barcelona (Sección 16ª, 31.7.2000) estimó íntegramente el recurso de apelación y condenó a los demandados a pagar 8.961.322,55 € a "Lepanto", 1.526.244,80 € a Luís Enrique, 846.379,26 € a "Penedés, S.A." y 65.599,71 € a "Alto Penedés, S.A.".

El TS estimó el recurso de casación interpuesto por "Price Waterhouse Auditores, S.A." e Iván y revoca la SAP y dictó una nueva sentencia. El hecho de que la CNMV no hubiera actuado a tiempo para impedir las inversiones efectuadas por los demandantes es una causa extraña al ámbito de protección de la norma a cuya infracción se vincula la responsabilidad del auditor (art. 11 Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas – ahora art. 22 RDL 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas), pues la finalidad de esta norma es permitir que tanto la sociedad auditada como los terceros pudieran conocer la calidad de la información económico contable sobre la cual versaba la opinión emitida por el auditor de cuentas.

2.1.1.6. Situaciones de peligro que requieren acción inmediata: **Sudden emergency doctrine**

Una emergencia es, dice el DRAE, una "situación de peligro que requiere una acción inmediata" (3ª acepción) y la pregunta es si, ante una emergencia, los deberes de precaución son menos intensos que ante una situación de riesgo normalmente esperable. La respuesta es que la emergencia se tiene en cuenta como una de las circunstancias que modulan los deberes de cuidado, pero que, probablemente, no hay necesidad de construir una doctrina específica en la cual quepa encasillar multitud de acontecimientos inesperados, pero muy heterogéneos entre sí.

***Lyons v. Midnight Sun Transportation Services, Inc.*(928 P.2d 1202 (Alaska 1996))** (http://www.onlinelawtutoring.com/Case_Reference/Lyons_v_Midnight_Sun_Transportation_Services_Inc_928_P2d_1202_1996.htm)

PER CURIAM.

I. FACTS AND PROCEEDINGS

Esther Hunter-Lyons was killed when her Volkswagen van was struck broadside by a truck driven by David Jette and owned by Midnight Sun Transportation Services, Inc. When the accident occurred, Jette was driving south in the right-hand lane of Arctic Boulevard in Anchorage. Hunter-Lyons pulled out of a parking lot in front of him. Jette braked and steered to the left, but Hunter-Lyons continued to pull out further into the traffic lane. Jette's truck collided with Hunter-Lyons's vehicle. David Lyons, the deceased's husband, filed suit, asserting that Jette had been speeding and driving negligently.

At trial, conflicting testimony was introduced regarding Jette's speed before the collision. Lyons's expert witness testified that Jette may have been driving as fast as 53 miles per hour. Midnight Sun's expert testified that Jette probably had been driving significantly slower and that the collision could have occurred even if Jette had been driving at the speed limit, 35 miles per hour. Lyons's expert later testified that if Jette had stayed in his own lane, and had not steered to the left, there would have been no collision. Midnight Sun's expert contended that steering to the left when a vehicle pulls out onto the roadway from the right is a normal response and is generally the safest course of action to follow.

Over Lyons's objection, the jury was given an instruction on the sudden emergency doctrine. The jury found that Jette, in fact, had been negligent, but his negligence was not a legal cause of the accident. Lyons appeals, arguing that the court should not have given the jury the sudden emergency instruction.

II. ANALYSIS AND DISCUSSION

The sudden emergency doctrine is a rule of law which states that a person confronted with a sudden and unexpected peril, not resulting from that person's own negligence, is not expected to exercise the same 1204 judgment and prudence the law requires of a person in calmer and more deliberate moments. The person confronted with the imminent peril must, however, act as a reasonable person would under the same conditions.

[The Court first held that the use of the sudden emergency instruction count was harmless error since the jury decided in favour of defendant on the ground that his conduct was not the legal cause of plaintiff's injury.]

B. Sudden Emergency Instruction Disapproved

[W]e take this opportunity to disapprove of the instruction's further use. It adds nothing to the established law that the duty of care, which all must exercise, is to act reasonably under the circumstances. The instruction is potentially confusing. Although we cannot say that the instruction is never appropriate, we discourage its employment. In support of this admonition, we offer the following background.

The sudden emergency doctrine arose as a method of ameliorating the, sometimes harsh, "all or nothing" rule in contributory negligence systems. […]

Although the doctrine came out of the contributory negligence regime, there is nothing about it which is inherently incompatible with a comparative fault system. Comparative negligence is a method of apportioning liability for a particular accident among the various parties who have been deemed negligent. The sudden emergency doctrine, in turn, is an expression of the applicable standard of care against which particular actions are judged in order to determine whether they were negligent in character. The fault of one person, determined in the light of a sudden emergency instruction, can be compared to the fault of another person, whose negligence may have created the emergency, with no logical inconsistency. […]

We believe that the sudden emergency instruction is a generally useless appendage to the law of negligence. With or without an emergency, the standard of care a person must exercise is still that of a reasonable person under the circumstances. With or without the instruction, parties are still entitled to present evidence at trial which will establish what the circumstances were, and are also entitled to argue to the jury that they acted as a reasonable person would have in light of those circumstances. Thus, barring circumstances that we cannot at the moment hypothesize, a sudden emergency instruction serves no positive function. Further, the instruction may cause confusion by appearing to imply that one party is less blameworthy than the other. Therefore, we hold that it should not be used unless a court finds that the particular and peculiar facts of a case warrant more explanation of the standard of care than is generally required […].

AFFIRMED.

§ 9 Restatement (Third) of Torts:

"If an actor is confronted with an unexpected emergency requiring rapid response, this is a circumstance to be taken into account in determining whether the actor´s resulting conduct is that of the reasonable careful person".

- This section addresses the situation in which an actor faces two or more choices of conduct, each of which entails its own combination of advantages and disadvantages. In an emergency, the fact of the emergency itself may mean that the response is instinctive rather than deliberative; at the least, it indicates that the opportunities for deliberation have been limited by severe time pressures.

- The emergency can be created by the conduct of another person, or without human action (failure of the brakes).

- Emergency. The kind of event that prevents reasonable people from exercising the kind of good judgment that such people ordinarily exercise.

- Prior negligence of the defendant. A number of courts adopt the rule that the emergency doctrine does not apply when the emergency is due to the defendant´s prior negligence, but not all.

Sesión 4ª

2.2. Cálculo del riesgo. Concepto económico de culpa / *Calculus of risk. The Economic Concept of Negligence*

La idea de que, en un mundo finito, con recursos limitados, la precaución que hay que aplicar a la realización de una actividad lícita, pero peligrosa, no es infinita es muy antigua:

2.2.1. *Eckert v. Long Island R.R.* (43 N.Y. 502 (1871))

"[...] The case, as made by the plaintiff, was that the deceased received an injury from a locomotive engine of the defendant, which resulted in his death, on the 26th day of November, 1867, under the following circumstances :

He was standing in the afternoon of the day named, in conversation with another person about fifty feet from the defendant's track in East New York, as a train of cars was coming in from Jamaica at a rate of speed estimated by the plaintiff's witnesses of from twelve to twenty miles an hour. The plaintiff's witnesses heard no signal either, from the whistle or the bell upon the engine. The engine was constructed to run either way without turning and it was then running backward with the cowcatcher next the train it was drawing, and nothing in front to remove obstacles from the track. The claim of the plaintiff was that the evidence authorized the jury to find that the speed of the train was improper and negligent in that particular place, it being a thickly populated neighborhood and one of the stations of the road.

The evidence on the part of the plaintiff also showed that a child three or four years old was sitting or standing upon the track of the defendant's road as the train of cars approached and was liable to be run over, if not removed; and the deceased, seeing the danger of the child, ran to it, and, seizing it, threw it clear of the track on the side opposite to that from which he came, but, continuing across the track himself, was struck by the step or some part of the locomotive or tender, thrown down, and received injuries from which he died the same night.

The evidence on the part of the defendant tended to prove that the cars were being run at a very moderate speed, not over seven or eight miles an hour, that the signals required by law were given, and that the child was not on the track over which the cars were passing, but on a side track near the main track.

So far as there was any conflict of evidence or question of fact, the questions were submitted to the jury. At the close of the plaintiff's case, the counsel for the defendant moved for a nonsuit upon the ground that it appeared that the deceased's negligence contributed to the injury and the motion was denied and an exception taken. After the evidence was all in, the judge was requested by the counsel for the defendant to charge the jury, in different forms, that if the deceased voluntarily placed himself in peril from which he received the injury, to save the child, whether the child was or was not in danger, the plaintiff could not recover and all the requests were refused and exceptions taken, and the question whether the negligence of the intestate contributed to the accident was submitted to the jury. The jury found a verdict for the plaintiff and the judgment entered thereon was affirmed, on appeal, by the Supreme Court and from the latter judgment the defendant has appealed to this court.

GROVER, J. The important question in this case arises upon the exception taken by the defendant's counsel to the denial of his motion for a nonsuit, made upon the ground that the negligence of the plaintiff's intestate contributed to the injury that caused his death. The evidence showed that the train was approaching in plain view of the deceased, and had he for his own purposes attempted to cross the track, or with a view to save property placed himself voluntarily in a position where he might have received an injury from a collision with the train,

his conduct would have been grossly negligent, and no recovery could have been had for such injury. But the evidence further showed that there was a small child upon the track, who, if not rescued, must have been inevitably crushed by the rapidly approaching train. This the deceased saw, and he owed a duty of important obligation to this child to rescue it from its extreme peril, if he could do so without incurring great danger to himself. Negligence implies some act of commission or omission wrongful in itself. Under the circumstances in which the deceased was placed, it was not wrongful in him to make every effort in his power to rescue the child, compatible with a reasonable regard for his own safety. It was his duty to exercise his judgment as to whether he could probably save the child without serious injury to himself. If, from the appearances, he believed that he could, it was not negligence to make an attempt so to do, although believing that possibly he might fail and receive an injury himself. He had no time for deliberation. He must act instantly, if at all, as a moment's delay would have been fatal to the child. The law has so high a regard for human life that it will not impute negligence to an effort to preserve it, unless made under such circumstances as to constitute rashness in the judgment of prudent persons. For a person engaged in his ordinary affairs, or in the mere protection of property, knowingly and voluntarily to place himself in a position where he is liable to receive a serious injury, is negligence which will preclude a recovery for an injury so received; but when the exposure is for the purpose of saving life it is not wrongful, and therefore not negligent, unless such as to be regarded either rash or reckless. The jury was warranted in finding the deceased free from negligence under the micas above stated. The motion for a nonsuit was therefore properly denied. That the jury was warranted in finding the defendant guilty of negligence in running the train in the manner it was running requires no discussion. None of the exceptions taken to the charge as given, or to the refusals to charge as requested, affect the right of recovery. Upon the principle above stated, the judgment appealed from must be affirmed, with costs.

CHURCH, C. J., and PECKHAM and RAPALLO, JJ., concur.

ALLEN, J., wrote a dissenting opinion, in which FOLGER, J., concurred.

Judgment affirmed".

En la jurisprudencia española, la idea de que la precaución exigible ha de ser conmensurable con el riesgo aparece en muchas sentencias, pero casi nunca de forma central:

2.2.2. STS, 1ª, 1186/2004, de 10 de diciembre

El 18.8.1990, José Manuel intentó socorrer a otra persona que se estaba ahogando en la playa de Cullera (Valencia) en una zona alejada de la de uso habitual de los bañistas, sin que existiera en las cercanías miembros del servicios de socorristas municipales y cuando el mar estaba picado. A pesar de que una zódiac de socorristas acudió a rescatarles, ambos fallecieron.

La viuda, en nombre propio y en el de su hijo, demandó al Ayuntamiento de Cullera y solicitó una indemnización de 120.202,42 €.

El JPI nº 1 de Sueca estimó la demanda (2.7.1996) y condenó al Ayuntamiento al pago de 102.172 €, de los cuales 72.121,45 € para la actora y 30.050,60 € para su hijo. La AP de Valencia (Secc. 8ª, 4.5.1998) estimó el recurso de apelación, revocó la SJPI y absolvió al Ayuntamiento.

El TS desestimó el recurso de casación al considerar que la actuación de la víctima fue negligente, pues no tuvo en consideración el mal estado del mar, y que la del equipo de salvamento fue adecuada: "el hecho en cuestión no puede ser reprochado culpabilísticamente al eventual responsable –el Ayuntamiento de Cullera- ya que aparte de la actuación personal del fallecido creadora del riesgo por su comportamiento, que aunque impregnado de un sentimiento solidario de amistad y altruismo, no tuvo en cuenta el mal cariz que presentaba el mar, que en ese momento suponía un peligro serio"(FD 1º).

En el caso debe tenerse en cuenta el criterio de la provocación, según el cual debe afirmarse la imputación objetiva del daño cuando el dañado asume el riesgo del que finalmente resulta

víctima en su intento de salvar la vida, integridad física o bienes de un tercero en situación de peligro creada negligentemente por la víctima misma.

Obviando la posible responsabilidad de la persona a quien se intentó salvar–que la actora parece olvidar aferrándose a una entidad más solvente, el Ayuntamiento- , la cuestión radica en determinar si el Ayuntamiento, en concreto, los servicios de salvamento, incumplieron, por omisión, el deber de interrumpir el curso causal anteriormente mencionado.

Puede pensarse que, dada la autopuesta en peligro –o, dicho de otro modo, la asunción del riesgo- por parte de los bañistas, la Administración no incumplió su deber de protección y salvamento, pues no tiene la obligación de prever todo tipo de accidentes ni de proveer servicios de salvamento de forma que se reduzca el número de accidentes hasta cero, incluyendo los gravemente negligentes.

En este sentido, según el TS, la actuación de los servicios de salvamento fue "lógica y correcta", pues "no se puede exigir que haya una abundancia tal de socorristas que puedan actuar de inmediato"(FD 1º).

U.S. v. Carroll, resuelto en 1947, es el caso de derecho de daños más famoso del siglo XX quizás porque acuñó el concepto económico de negligencia en el cénit cultural de un sistema económico. Todavía hoy, es inconcebible un curso de responsabilidad civil impartido en cualquiera de las cincuenta facultades de derecho más prestigiosas según los rankings al uso que no mencione *U.S. v. Carroll*, aunque solo sea para tratar de superarlo. Como ha de ser:

2.2.3. *United States v. Carroll Towing Co.* (159 F.2d 169 (2d Cir. 1947))

[The incident out of which this admiralty case arose was the sinking of a barge, along with its cargo, allegedly because of the defendant's negligence. A crucial issue in the case involved whether the person in charge of the barge, the barge, was negligent in being ashore, away from the barge, during the period when the barge got into difficulties and sank. If the barge's absence was negligence, and if it contributed substantially to the loss of the barge, then the barge's employer, the owner of the barge, would not receive full recovery from the other parties whose negligence put the barge into difficulties in the first place].

L. HAND, J.
It appears … that there is no general rule to determine when the absence of a barge or other attendant will make the owner of the barge liable for injuries to other vessels if she breaks away from her moorings. However, in any cases where he would be so liable for injuries to others obviously he must reduce his damages proportionately, if the injury is to his own barge. It becomes apparent why there can be no such general rule, when we consider the grounds for such a liability. Since there are occasions when every vessel will break from her moorings, and since, if she does, she becomes a menace to those about her; the owner's duty, as in other similar situations, to provide against resulting injuries is a function of three variables:

(1) the probability that she will break away;
(2) the gravity of the resulting injury, if she does;
(3) the burden of adequate precautions.

Possibly it serves to bring this notion into relief to state it in algebraic terms: if the probability be called P; the injury, L; and the burden, B; liability depends upon whether B is less than L multiplied by P: i.e., whether B less than PL. Applied to the situation at bar, the likelihood that a barge will break from her fasts and the damage she will do, vary with the place and time; for example, if a storm threatens, the danger is greater; so it is, if she is in a crowded harbor where moored barges are constantly being shifted about. On the other hand, the barge must not be the barge's prison, even though he lives aboard; he must go ashore at times. We need not say whether, even in such crowded waters as New York Harbor a barge must be aboard at night at all; it may be that the custom is otherwise… and that, if so, the situation is one where custom should control. We leave that question open; but we hold that it is not in all cases a sufficient answer to a barge's absence without excuse, during working hours, that he has properly made

fast his barge to a pier, when he leaves her. In the case at bar the barge left at five o'clock in the afternoon of January 3rd, and the flotilla broke away at about two o'clock in the afternoon of the following day, twenty-one hours afterwards. The barge had been away all the time, and we hold that his fabricated story was affirmative evidence that he had no excuse for his absence. At the locus in quo- especially during the short January days and in the full tide of war activity- barges were being constantly 'drilled' in and out. Certainly it was not beyond reasonable expectation that, with the inevitable haste and bustle, the work might not be done with adequate care. In such circumstances we hold- and it is all that we do hold- that it was a fair requirement that the Conners Company should have a barge aboard (unless he had some excuse for his absence), during the working hours of daylight.

El remolcador de la compañía demandada remolcando una línea de barcazas o gabarras, aguas arriba y aguas abajo, en el río Hudson. La línea incluía la Anna C., propiedad de la Connors Company. La Anna C. rompió sus amarras y, llevada por el viento y la marea, abordó un petrolero cuya hélice rasgó el casco de la barcaza que, a continuación, se hundió.

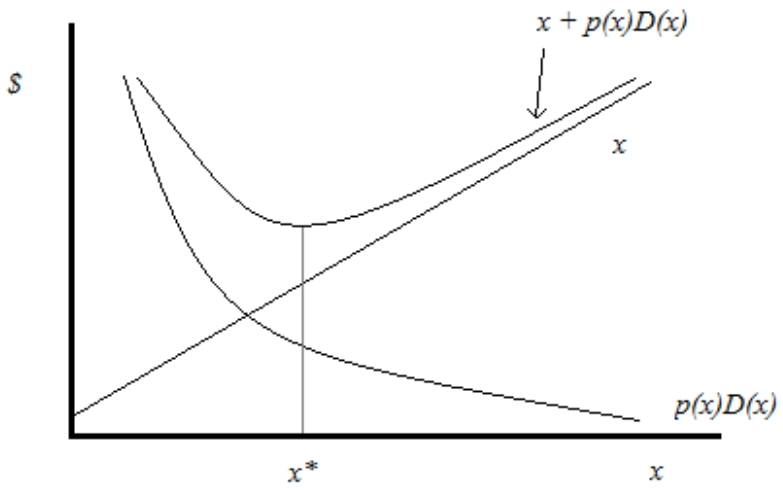
Una cuestión ante el tribunal era si el armador o dueño de la barraca había incurrido en negligencia, había sido contributivamente negligente, pues podría –se alegaba- haber destacado a un barge –gabarrero, marinero- en la barcaza.

Hand: No hay regla general, ni legal ni consuetudinaria que establezca cuándo la ausencia de un gabarrero, barquero hará al armador responsable por los daños derivados de la rotura de las amarras de la barcaza. Está claro por qué no puede haber una regla general semejante, pues hay ocasiones en las que cualquier barco se soltaría de sus amarras… El deber de cuidado del dueño es una función de tres variables: B = PL.

Puede ser que la costumbre sea distinta, en cuyo supuesto, gobernará el caso.

En la literatura: Richard POSNER, *A Theory of Negligence* 1 J. Legal Stud. 29 (1972).

Gráfico de John PRATER BROWN (1983)/Steven SHAVELL (1987).



§ 3 ("Negligence") The Restatement (Third) of Torts:

"A person acts negligently if the person does not exercise reasonable care under all the circumstances."

Primary factors to consider in ascertaining whether the person's conduct lacks reasonable care are:

1) The foreseeable likelihood that the person's conduct will result in harm.
2) The foreseeable severity of any harm that may ensue.
3) And the burden of precautions to eliminate or reduce the risk of harm.

Análisis crítico:

1) Una simple plantilla: *Judex non calculat*, es decir, los tribunales no son consultorías, sino que aplican el derecho a los hechos del caso, tal y como resultan probados en el proceso.
2) La objeción filosófica de la inconmensurabilidad y los problemas empíricos de medición: *Helling v. Carey* (519 P. 22d 981 (Wash. 1974)): entre los años 1859 y 1968, el demandante acudía a la consulta del oftalmólogo demandado para visitarse y tratarse de una irritación en los ojos causada por lentes de contacto. A finales de 1968, cuando el demandante tenía 32 años de edad, el demandado sospechó que aquel podría sufrir de glaucoma –una enfermedad de los ojos causada por un exceso de presión sobre el nervio óptico- cuando el paciente le dijo que había perdido visión periférica. El oftalmólogo le aplicó entonces un test de presión que confirmó el diagnóstico. El paciente acabó por perder la vista, pero un tratamiento temprano habría evitado el daño. En el pleito que siguió por mala praxis médica, el demandado alegó que el estándar profesional no exigía practicar pruebas de presión a pacientes menores de cuarenta años de edad, pues se trataba de una enfermedad muy poco común que sólo se presentaba en 1/25.000 casos. Suponiendo que el coste de cada test aplicado a cada niño o persona joven que se visite es de 5 USD, ¿había que haber practicado el test o no? Fíjense que tenemos B = 5, P: 1/25.000, pero que nos falta L, la evaluación de la pérdida de la visión. Si B = PL, entonces 5 = 125.000/25.000. Mas ¿cuánto vale un ojo de la cara?
3) Un caso similar, apropiado para ser discutido en un seminario, es la STS, 3ª, de 26 de junio de 2008: neuritis óptica de origen tóxico por tratamiento con medicación antituberculosa, Rifinah 300 (principio activo: isoniazida), reacción adversa, muy rara (que se produce en uno de cada diez mil tratamientos) y en caso en el que no existe indicación previa de propensión del paciente a neuritis.
4) Otra cuestión derivada de la presencia masiva de falsos positivos, que encarece mucho la práctica del test: si el test de presión sale positivo en muchos casos, de forma tal que sólo el 4% de los positivos es auténtico, es decir, desarrollarán glaucoma, la cosa se complica. Volveremos sobre la conveniencia o inconveniencia de estar a los estándares profesionales, a la costumbre.
5) Precaución absoluta o precauciones marginales: los primeros 60 euros o dólares USA evitan daños por una evaluación de 120, pero los segundos 40 sólo 30. Entonces, aunque (60 + 40 =) 100 <(120 + 30)= 150, es mejor, menos malo quedarse en 60 de gasto en precauciones, pues los segundos 40 superan en 10 a los 30 que se ahorran con ellos. Si no aprecian contar en unidades económicas, en dinero, pueden hacerlo en cualquier otra unidad que no les repela, por ejemplo, en *quality adjusted years of life, QUALY's.*
6) La fórmula no captura el autorriesgo (PORAT-COOTER, 29 J. Legal, Stud 19 (2000)), la autopuesta en riesgo, es decir, que no tiene en cuenta los daños probables causados por el comportamiento del demandado a sus propios bienes y, que en tal sentido, no incentiva la adopción óptima de precauciones.

7) La neutralidad al riesgo es poco plausible como supuesto general: muchas personas prefieren un 10% de probabilidad de perder 100 al 100% de perder 10. La función de utilidad crece menos que proporcionalmente que la renta.
8) ¿Por qué es negligente la gente? Si es racional, no debería serlo.
9) Discontinuidades: pequeños errores en la apreciación del estándar llevan a discontinuidades en la función de responsabilidad: el médico cirujano pasa de ser un prudente profesional a un homicida negligente. Por un pequeño error. Y
10) ¿Sabemos realmente calcular las consecuencias de todas y de cada una de nuestras decisiones arriesgadas para nosotros mismos y para los demás? ¿Lo hacemos así?.

2.3. Negligencia como incremento irrazonable de riesgo / *Negligence as non-reasonable increase of risk*

Tal y como se ha venido señalando en estas en estas Sesiones, la otra cara de la definición de la negligencia concebida como infracción de deberes de cuidado es su concepción como incremento irrazonable de un riesgo. En el contexto del análisis de la regla de Hand, *Helling v. Carey* ilustra muy claramente este enfoque:

2.3.1. *Helling v. Carey* (83 Wash. 2d 514, 519 P.2d 981 (1974))

HUNTER, ASSOCIATE JUSTICE. This case arises from a malpractice action instituted by the plaintiff (petitioner), Barbara Helling.

The plaintiff suffers from primary open angle glaucoma. Primary open angle glaucoma is essentially a condition of the eye in which there is an interference in the ease with which the nourishing fluids can flow out of the eye. Such a condition results in pressure gradually rising above the normal level to such an extent that damage is produced to the optic nerve and its fibers with resultant loss in vision.... The disease usually has few symptoms and, in the absence of a pressure test, is often undetected until the damage has become extensive and irreversible.

The defendants (respondents), Dr. Thomas F. Carey and Dr. Robert C. Laughlin, are partners who practice the medical specialty of ophthalmology. Ophthalmology involves the diagnosis and treatment of defects and diseases of the eye.

The plaintiff first consulted the defendants for myopia, nearsightedness, in 1959. At that time she was fitted with contact lenses. [She consulted the defendants several times over the next nine years.] Until the October 1968 consultation, the defendants considered the plaintiff's visual problems to be related solely to complications associated with contact lenses. On that occasion, the defendant, Dr. Carey, tested the plaintiff's eye pressure and field of vision for the first time. This test indicated that the plaintiff had glaucoma. The plaintiff ... was then 32 years of age.

Thereafter, in August of 1969, after consulting other physicians, the plaintiff filed a complaint against the defendants alleging, among other things, that she sustained severe and permanent damage to her eyes as a proximate result of the defendants' negligence. During trial, the testimony of the medical experts for both the plaintiff and the defendants established that the standards of the profession for that specialty in the same or similar circumstances do not require routine pressure tests for glaucoma upon patients under 40 years of age. The reason the pressure test for glaucoma is not given as a regular practice to patients under the age of 40 is that the disease rarely occurs in this age group. Testimony indicated, however, that the standards of the profession do require pressure tests if the patient's complaints and symptoms reveal to the physician that glaucoma should be suspected.

The trial court entered judgment for the defendants following a defense verdict. The plaintiff thereupon appealed to the Court of Appeals, which affirmed the judgment of the trial court (...).

We find this to be a unique case. (…) The issue is whether the defendants' compliance with the standard of the profession of ophthalmology, which does not require the giving of a routine pressure test to persons under 40 years of age, should insulate them from liability under the facts in this case where the plaintiff has lost a substantial amount of her vision due to the failure of the defendants to timely give the pressure test to the plaintiff.

The incidence of glaucoma in one out of 25,000 persons under the age of 40 may appear quite minimal. However, that one person, the plaintiff in this instance, is entitled to the same protection as afforded persons over 40, essential for timely detection of the evidence of glaucoma where it can be arrested to avoid the grave and devastating result of this disease. The test is a simple pressure test, relatively inexpensive. There is no judgment factor involved, and there is no doubt that by giving the test the evidence of glaucoma can be detected. The giving of the test is harmless if the physical condition of the eye permits. The testimony indicates that although the condition of the plaintiff's eyes might have at times prevented the defendants from administering the pressure test, there is an absence of evidence in the record that the test could not have been timely given (...).

Under the facts of this case reasonable prudence required the timely giving of the pressure test to this plaintiff. The precaution of giving this test to detect the incidence of glaucoma to patients under 40 years of age is so imperative that irrespective of its disregard by the standards of the ophthalmology profession, it is the duty of the courts to say what is required to protect patients under 40 from the damaging results of glaucoma.

We therefore hold, as a matter of law, that the reasonable standard that should have been followed under the undisputed facts of this case was the timely giving of this simple, harmless pressure test to this plaintiff and that, in failing to do so, the defendants were negligent, which proximately resulted in the blindness sustained by the plaintiff for which the defendants are liable (...).

The judgment of the trial court and the decision of the Court of Appeals is reversed, and the case is remanded for a new trial on the issue of damages only.

En la jurisprudencia española, la problemática abordada por Helling aparece en numerosas sentencias. Destacamos algunas:

2.3.2. STS, 3ª, de 26 de junio de 2008.

En abril de 1999, el Sr. Octavio acudió a un Centro de Atención Primaria de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) donde el Dr. Millán, médico de cabecera del actor, le diagnosticó tuberculosis, que no fue confirmada por médico especialista, e inició tratamiento farmacológico con Rifinah (F: Sanofi Aventis, S.A.; PA: Isoniazida, Rifampicina; AT: tratamiento de la tuberculosis). En agosto de 1999, se retiró la medicación al Sr. Octavio porque su consumo le había causado una neuritis óptica bilateral, lo que devino en una incapacidad permanente absoluta. Consta acreditado que la neuritis óptica es una reacción poco frecuente (1/10.000 tratamientos) de la isoniazida y que puede paliarse con vitamina B 6, que no se le administró al paciente.

El Sr. Octavio interpuso, primero, reclamación administrativa contra la Administración General del Estado, el Instituto Nacional de la Salud y Mapfre Industrial, S.A. en la que solicitaba 26 millones de ptas. (156.263 euros), que fue desestimada por silencio administrativo y, después, recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que también fue desestimado (3.3.2004). El actor interpuso finalmente recurso de casación.

El TS estimó dicho recurso de casación, en el que se alegaba infracción del art. 141.1 Ley 30/1992, y condenó a la Administración General del Estado al pago de 30.000 euros porque "debe entenderse que siendo médicamente conocidos los efectos secundarios de la administración de isoniacida y que estos hubieran podido, si no prevenirse, sí minimizarse con la administración conjunta de la vitamina B 6, la no pautación de dicha vitamina al recurrente, a

quien como a cualquier paciente, según el informe pericial, se le podían producir dichos efectos secundarios, sin olvidar además que al mismo no se le había realizado prueba que hubiese permitido una mejor confirmación del diagnóstico de presunción, supone una infracción de la "lex artis" que le ha generado una pérdida de oportunidad, en cuanto los resultados hubieran podido ser otros, si se le hubiese administrado conjuntamente la vitamina B 6" (FD 5ª).

2.3.3. STS, 1ª, 150/2008, de 28 de febrero

El 20.9.1992, el Dr. Braulio operó a Rodolfo de hernia discal. Sin embargo, operó el disco L3-L4 y no el L4-L5, que era el objeto de la intervención. Consta que el disco L3-L4 estaba dañado en forma de profusión coincidente con el L4-L5.

Rodolfo demandó a Braulio en petición de una indemnización de 150.253,03 €.

El JPI núm. 1 de Langreo (29.11.1999) desestimó la demanda. La AP de Oviedo (Sección 5ª, 2.11.2000) desestimó el recurso de apelación.

El TS desestimó el recurso de casación. El actor no ha probado que el disco L3-L4 estuviera sano, así como tampoco que su situación actual guarde relación alguna con la operación (FD 4º).

2.3.4. STS, 1ª, 64/2011, de 9 de febrero

El 3.3.2001, Isaac esquiaba en la estación de La Molina (propiedad de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), junto a su familia, cuando cayó y se deslizó hasta impactar contra un cañón de nieve artificial. A raíz del accidente, a Isaac se le rompieron las vértebras D7, D8, D11 y D12, pertenecientes a dos zonas diferentes de la columna, y sufre paraplejia L1, con afectación de esfínteres rectales y urinarios.

Isaac y su mujer África demandaron, en su nombre y en el de sus tres hijas menores de edad –Maite, Melisa y Noemí–, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y a su aseguradora Winterthur y solicitaron una indemnización por los daños y perjuicios sufridos (no consta cuantía).

El JPI nº 7 de Barcelona (15.12.2004) estimó en parte la demanda y condenó a las demandadas (a Winterthur solamente hasta los 300.005,99€) al pago de 646.803,97€ a Isaac y de 90.000€ a Isaac y a África por el daño moral causado a la mujer y a las hijas del actor.

La AP de Barcelona (Sección 1ª, 20.9.2006) estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por los actores y aumentó la indemnización a pagar por las demandadas a 790.220,60€ a Isaac y a 110.000 € al matrimonio y a sus hijas.

El TS desestimó el recurso de casación interpuesto por los demandados:

"(…) debe juzgarse como razonable la decisión de calificar como no diligente la conducta de la empresa titular de la estación pues […] el dueño de una estación de esquí se encuentra obligado a poner los medios adecuados para evitar el daño teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que gestiona, y con mayor motivo, cuando contribuyó a incrementar el riesgo propio de la actividad deportiva colocando en un lugar próximo a la pista un elemento artificial, rígido y duro, como un cañón artificial, que generó un riesgo evidente de lesiones en caso de colisión, incluso si esta se producía por consecuencia de un deslizamiento subsiguiente a una caída. Y siendo todo ello previsible, las caídas, las colisiones y el daño, no podía limitarse a señalar el elemento sino que le incumbía adoptar medidas de seguridad encaminadas a evitar o a disminuir el riesgo de lesiones, lo que no hizo". (FD 4º)

Vídeo de un accidente similar en Vallter 2000 en el año 2008
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/11638/el-terrible-accidente-en-la-nieve-que-costo-la-vida-a-un-joven-colombiano-en-espana/

2.3.5. STS, 1ª, 149/2010, de 25 de marzo

Una mujer de 65 años de edad y con problemas óseos y articulares, que habían determinado en 1987 el reconocimiento de una situación de invalidez absoluta, no advirtió que, en la entrada de un restaurante había un escalón, por lo que tropezó y se cayó. Como resultado de la caída, sufrió facturas del subcapital de fémur derecho, de la vértebra C1 sin desplazamiento y de la vértebra C2, que agravaron su artrosis previa. La víctima demandó a la sociedad limitada propietaria del restaurante y a su compañía de seguros. El JPI desestimó la demanda. La AP estimó en parte el recurso de apelación de la actora y condenó a los demandados al pago de 45.076 euros. El TS desestimó el recurso de casación de los demandados y confirmó la SAP:

"[E]l tribunal de apelación no infringió el art. 1902 CC (…) porque en definitiva esta Sala sí comparte el juicio esencial de dicho tribunal sobre la negligencia inherente a la disposición o configuración del acceso del hostal al restaurante, con un escalón intermedio a escasísima distancia del umbral y precisamente en la zona de claroscuro provocado, simultáneamente, por los diferentes colores del pavimento y la luz solar a la entrada y al fondo, quedando en penumbra precisamente el punto en que se encontraba el escalón (…) [L]a causa de la caída no fue sólo esa omisión negligente dado que también contribuyó de forma importante el estado físico de la demandante que afectaba a su capacidad de deambulación. En suma, el problema no es tanto de culpa de la víctima, pues ninguna culpa hay en padecer enfermedades o limitaciones ósea y articulares, cuanto de imputación al demandado de la causa de lo sucedido y de sus consecuencias (FD. 4º).

2.4. Costumbre / *Custom*

Pablo SALVADOR CODERCH - La costumbre como fuente de los deberes de precaución

La costumbre, los usos de la profesión, arte u oficio, sus buenas prácticas, son índices de calidad, de conducta adecuada, por diligente, del demandado, pero son solo eso: indicios, pues ni siquiera constituyen una presunción en sentido estricto. Por cierto, ¿conoce el lector la distinción entre presunciones, indicios y sospechas?

En cualquier caso, para valorar el comportamiento del demandado, hay que tener en cuenta, en primerísimo lugar, las disposiciones de la ley o, más frecuentemente, de los reglamentos que la desarrollan en tema de estándares de precaución. Aquí es importante destacar que, entre la ley

(y el reglamento), por un lado, y la costumbre, hay muchas posibilidades alternativas. Véase si no, la lista siguiente:

[First of all, statutory standards of care have to be taken into account:

a. Specific Safety Regulations.
b. Best Available Technology (BAT)
c. As Low As Reasonably Achievable (ALARA)
d. Cost-benefit: Entergy Corp. v. Riverkeeper Inc. et al.
e. The utmost care standard…
f. …

And then, there is:]

g. Custom

The general principles of negligence ("The reasonable person standard"), writes Epstein (p. 221), leave judges a great deal of latitude in deciding cases. This generality introduces a large element of uncertainty even in ostensible routine cases. Using custom to set the standard of care is one way to reduce this uncertainty.

The question is then: Should custom be given the same deference in actions between strangers as in actions arising out of consensual relationships? Does "reasonable safe" mean "safe according to the usages, habits, and ordinary risks of the business"? See *Titus v. Bradford, B & K*. R. Co. 20 A. 517 (Pa. 1890).

El caso de referencia sobre usos, costumbre y tecnología es *The T.J. Hopper*. Resuelto hace ochenta años, su lectura es todavía un magnífico punto de partida para el análisis de la cuestión de si la costumbre induce diligencia:

2.4.1. *The T.J. Hooper* (60 F.2d 737 (2d Cir.), cert. denied, 287 U.S. 662 (1932))

Petition by the Eastern Transportation Company, as owner of the tugs Montrose and T. J. Hooper, for exoneration from, or limitation of, liability; separate libels by the New England Coal & Coke Company and by H. N. Hartwell & Son, Inc., against the Northern Barge Corporation, as owner of the barge Northern No. 30 and the barge Northern No. 17; and libel by the Northern Barge Corporation against the tugs Montrose and Hooper. The suits were joined and heard together. From the decree rendered [53 F.(2d) 107], the petitioner Eastern Transportation Company and the Northern Barge Corporation, appeal.

[The operator of a tugboat was sued for the value of two barges and their cargoes, which were lost at sea during a coastal storm in March 1928. The basis of the claim was that the tug was negligently unseaworthy in that it was not equipped with a radio receiver, and thus could not receive reports of an impending storm. There was evidence that the master, had he heard the weather reports, would have turned back]

L. HAND,

It is not fair to say that there was a general custom among coastwise carriers so to equip their tugs. One line alone did it; as for the rest, they relied upon their crews, so far as they can be said to have relied at all. An adequate receiving set suitable for a coastwise tug can now be got at small cost and is reasonably reliable if kept up; obviously it is a source of great protection to their tows. Twice every day they can receive these predictions, based upon the widest possible information, available to every vessel within two or three hundred miles and more. Such a set is the ears of the tug to catch the spoken word, just as the master's binoculars are her eyes to see a storm signal ashore. Whatever may be said as to other vessels, tugs towing heavy coal laden barges, strung out for half a mile, have little power to manoeuvre, and do not, as this case

proves, expose themselves to weather which would not turn back stauncher craft. They can have at hand protection against dangers of which they can learn in no other way.

Is it then a final answer that the business had not yet generally adopted receiving sets? There are, no doubt, cases where courts seem to make the general practice of the calling the standard of proper diligence; we have indeed given some currency to the notion ourselves. Indeed in most cases reasonable prudence is in fact common prudence; but strictly it is never its measure; a whole calling may have unduly lagged in the adoption of new and available devices. It never may set its own tests, however persuasive be its usages. Courts must in the end say what is required; there are precautions so imperative that even their universal disregard will not excuse their omission. But here there was no custom at all as to receiving sets; some had them, some did not; the most that can be urged is that they had not yet become general. Certainly in such a case we need not pause; when some have thought a device necessary, at least we may say that they were right, and the others too slack. The statute (section 484, title 46, U. S. Code [46 USCA § 484]) does not bear on this situation at all. It prescribes not a receiving, but a transmitting set, and for a very different purpose; to call for help, not to get news. We hold the tugs therefore because had they been properly equipped, they would have got the Arlington reports. The injury was a direct consequence of this unseaworthiness.

Decree affirmed.

The Restatement (Third) of Torts "downgrades the role of custom" (Epstein) holding that compliance with the custom of the community is evidence that the actor's conduct is not negligence, but does not preclude a finding of negligence".

§ 13 RTT. Custom

(a) An actor's compliance with the custom of the community, or of others in like circumstances, is evidence that the actor's conduct is not negligent but does not preclude a finding of negligence.

(b) An actor's departure from the custom of the community, or of others in like circumstances, in a way that increases risk is evidence of the actor's negligence but does not require a finding of negligence.

Epstein's dissenting analysis from The T. J. Hooper:

Hand's view has received overwhelming acceptance. Epstein disagrees. First, in cases that arise out of a consensual arrangement, negligence is often the appropriate standard of liability, and where it is so, custom should be regarded as conclusive evidence of due care in absence of any contractual stipulation to the contrary. Second, in stranger cases, negligence should normally not be the appropriate standard of care, so that reliance on custom is as irrelevant as the negligence issue to which custom alone is properly directed (…) because it registers the preferences of the parties to the custom, not those who are victimized by it.

Compare: custom in international law –as a source of legal obligations-; custom in contract law.

Discuss:

- Compliance with the custom of the community. Widespread reliance on custom.
- Private standards ("codes") and public recommendations. Example: National Electric Safety Code, issued by the American National Standards Institute.
- Actor's departure from the custom of the community (typically: a large-scale defendant that has adopted standards applicable to its own operations or its own employees). Departure impugns any claim by the defendant that the risk is unforeseeable or that the safety practice is unfeasible. What happens when the actor departs from its own standard? The main question is the admissibility of introducing evidence regarding the defendant's violation of its own standard as admissible on the issue of negligence. Divided results. Grounds: if the admission of evidence is to be used against the defendant as an admission of departure, he would naturally

find it to his interest NOT to adopt any rules at all. Counterargument: The defendant itself had made these decisions, *facta propria*.

Trimarco v. Klein (N.Y. 1982): plaintiff injured in 1976 when he slipped in his bathroom and received serious lacerations from crashing against a shower door made of ordinary glass estimated to be between 1/16 and ¼ an inch thick. The shower had been installed in the 1950´s, when the use of ordinary glass was standard practice. Since the mid-60´s , the common practice in NYC had been to use safer tempered glass… Must all old shower doors be replaced? Sprinklers and burglar alarms be retrofitted in old buildings?

Why should conformity to the practice protect a physician from liability? One good ground: no other standard is practical. The battle of the experts. The (technical) incompetence of courts.

Local or national standards?: "The time has come when the medical profession should no longer be Balkanized by the application of varying geographic standards" (Brune v. Bellinkoff, Mass 1968). The proper standard is whether the physician has exercised the degree of care and skill of the average qualified practitioner, taking into account the advances in the profession.

Read:

Kenneth S. ABRAHAM, *Custom, Non-customary Practice, and Negligence*, 109 Colum , l. Rev. 1784 (2009).

2.4.2. Pablo SALVADOR CODERCH/Antonio FERNÁNDEZ CRENDE, "Instrumentos de control social y derecho de daños", *InDret* 4/2004 (www.indret.com), pp. 10-12

El Derecho de Daños como instrumento de control social: un ejemplo sencillo aplicado a la instalación de dispositivos ABS para vehículos

Para ilustrar cómo el derecho, y el derecho de daños en particular, contribuye a pasar de peores a mejores situaciones puede servir un ejemplo inspirado en otro que se puede encontrar en SCÄFER/OTT(2000) y que hemos reformulado para adaptarlo al sistema de frenado ABS (***Anti-Block System***) para automóviles. Éste es un dispositivo electrónico antibloqueo que controla la presión de líquido de los frenos y de esta forma evita que las ruedas se bloqueen cuando se ejerce una presión excesiva sobre el pedal, generalmente en situaciones de alto riesgo. En 1978, Mercedes Benz instala el primer sistema ABS en un coche de serie como sistema opcional. Con posterioridad, muchas firmas lo incorporaron a sus vehículos como equipo de serie, aunque todavía no era obligatorio[2].

Es indudable que este dispositivo mejora la capacidad de frenado de un vehículo bajo cualquier circunstancia por lo que evita accidentes individuales y también colectivos. Pero además, si todos disponen del mismo, contribuye a disminuir en gran medida la probabilidad de colisión entre vehículos. Es este segundo efecto el que nos interesa destacar aquí.

[2] El sistema de antibloqueo de ruedas al frenar (ABS) se convirtió en un dispositivo de serie obligatorio para todos los turismos nuevos vendidos en la Unión Europea a partir de 2003, en virtud de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión «Protección de los peatones: Compromiso de la industria europea del automóvil» (COM(2001) 389 — C5-0537/2001— 2001/2216(COS)), de 13 de junio de 2002 (P5_TA(2002)0323; DO C 261 E/576, de 30.10.2003). Sin embargo, la normativa se ha visto ya superada en este punto por el Reglamento (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 200\1, de 31.7.2009), el cual estableció el ESP (*Electronic Stability Control*, que incluye la función de ABS) como dispositivo de serie obligatorio en todos los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que se vendan en la Unión Europea desde el 1 de noviembre de 2011.

En un sencillo ejemplo, dos conductores (C1 y C2) barajan la posibilidad de instalar sendos sistemas de frenado ABS. La utilidad anual que cada conductor obtiene del disfrute de su automóvil es de 1200 €, y sus costes esperados serán de 600 € que resultan de una probabilidad del 6% de sufrir un accidente que le comportará daños por valor de 10.000 € (0,06 x 10.000). La instalación de un dispositivo de ABS tiene un coste de 100 € anuales ya que este sistema requiere de revisiones periódicas. Pero disponer de él reduce la probabilidad de sufrir un accidente de un 6% a un 2%, por lo que los costes esperados bajarán a 200 € (0'02 x 10.000).

Los *pay-offs* de una y otra opción para C1 y C2 figuran en la tabla siguiente:

		C2	
		ABS	NoABS
C1	ABS	900, 900	500, 600
	NoABS	600, 500	600, 600

Supongamos que C2 opta por instalar el ABS. Entonces C1 hará lo propio, pues 900 > 600 como podemos observar en la primera columna. Por el contrario, si C2 resuelve no instalarlo, C1 tampoco lo hará, pues estaremos en la segunda columna, 600 > 500. Si partimos de la decisión de C1 llegaremos a la misma conclusión, resultando las dos situaciones de equilibrio señaladas en la tabla. Se observa que existe un equilibrio eficiente (casilla superior izquierda) y otro ineficiente (casilla inferior derecha) que se corresponden con sendos equilibrios de Nash. A cuál de ellos se llegará, dependerá de circunstancias externas como señalan SCHÄFER y OTT para un ejemplo similar: si C1 sabe que C2 ha instalado el ABS, hará lo propio, pero si sabe que no lo ha hecho, tampoco lo hará él, pues un solo ABS no disminuye suficientemente la frecuencia y gravedad de las colisiones entre vehículos. *A priori*, bajo un sistema de ausencia de responsabilidad *(no liability rule)*, no hay garantías de que ninguna de las dos partes se comportará correctamente tras asumir que la otra lo hará.

Supongamos ahora una situación en la que existe una serie de n conductores C1, C2, C3,... Cn, para $1<n<\infty$ y p es la probabilidad de que un conductor haya instalado el sistema ABS en su vehículos. Entonces los beneficios esperados para C1 serán:

Beneficios en caso de ABS → $B(ABS)= p\cdot 900 + (1-p)\cdot 500= p\cdot 400 + 500$
Beneficios en caso de No ABS → $B(NoABS)= p\cdot 600 + (1-p)\cdot 600= 600$
(donde probabilidad: $p \in [0,1]$)

C1 optará por instalar ABS siempre que:

B(ABS)>B(NoABS), entonces:
$p\cdot 400 + 500 > 600$,
$p> 0'25$

De donde resulta que C1 instalará el ABS en su automóvil siempre que la probabilidad sea superior a 25%, esto es, cuando más de una cuarta parte de los vehículos dispongan de él, pero no lo hará si la proporción es inferior, pues no le saldrá a cuenta. El ejemplo ilustra un caso típico de instalación de dispositivos en los que se produce un efecto de externalidades de red – *network externalities*- ya que a mayor número de usuarios de un mismo producto o servicio, mayor será la utilidad que cada uno de ellos obtendrá de él. Pero, a pesar de que todos los interesados coincidan en que la difusión generalizada del producto sería socialmente beneficiosa, la existencia de dos equilibrios puede comportar que los sucesivos intentos de comercializar el uso del producto fracasen debido a que la red no esté lo suficientemente

extendida para crear los incentivos privados necesarios para la instalación. Pero un cambio de jurisprudencia o, por supuesto, de legislación podría dar un vuelco a esta situación: por ejemplo, si el Tribunal Supremo, ante un caso de reclamación de daños y perjuicios por colisión entre dos vehículos, resuelve que la falta de instalación de ABS es negligencia y que ésta reduce o anula la indemnización a que tendría derecho el actor, entonces ningún conductor podrá reclamar si no disponía de ABS y, en cambio, deberá pagar los daños resultantes al otro vehículo. Los pagos para C1 se verían modificados de la manera siguiente:

		C2, C3, C4,... Cn	
		ABS	NoABS
C1	ABS	900 900	0 1100
	NoABS	1100 0	600 600

(donde indemnización esperada: I = 0,06 x 10.000= 600)

Si instala ABS, en caso de colisión será indemnizado por aquél que fue negligente porque no lo instaló. En cambio, si no instala el sistema deberá pagar una indemnización a quién lo había instalado, o bien, en caso de que el otro tampoco lo hubiera instalado cada uno asumirá sus propios daños.

Podemos observar cómo independientemente de la decisión de los demás individuos, para C1 resulta más beneficioso instalar ABS ya que los pagos de la fila superior son siempre superiores a los de la inferior. De esta forma, el precedente jurisprudencial habría inducido los incentivos privados necesarios para la generalización del producto, que de otra forma no hubiera podido producirse".